

論憲法解釋原則*

陳淳文**

目次

壹、前言	一、憲法解釋原則具特殊性？
貳、憲法解釋原則的概念與形式	二、憲法解釋原則具個別性？
一、概念	三、憲法解釋原則之具體內容
二、形式與類型	伍、具體操作
參、憲法解釋原則之效力與功能	一、立法院院長選舉與人事同意權案
一、效力	二、司法院院長人事案
二、功能	陸、結語
肆、憲法解釋原則之內涵	

* 本文原發表於中央研究院法律學研究所於2018年12月15日所舉辦之「吳庚教授逝世週年紀念」學術研討會，後並通過審查刊載於中研院法學期刊，2019特刊2，頁139-209。

〔責任校對：鄭雅文〕。

** 國立臺灣大學政治學系暨公共事務研究所教授兼所長；中央研究院法律學研究所合聘研究員。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/40411102.pdf>。



壹、前言

吳庚教授在1990年8月於法令月刊發表〈論憲法解釋〉一文¹，是我國大法官於任職期間在期刊上公開表述釋憲方法的第一人。三年之後，他在同一期刊繼續發表〈法律解釋學初探〉一文²，這兩篇文章成為吳大法官卸任前於2003年4月出版之《憲法的解釋與適用》專書³中，有關憲法解釋章節的部分基礎。吳氏參與釋憲實務長達18年，對於憲法解釋情有獨鍾並不令人意外；比較值得注意的是：他為什麼要公開論述釋憲方法？單純的學術興趣自是理由之一，但也有可能是因吳氏對於不少大法官解釋之作成，著力甚深；但其所支持之見解在大法官內部遭遇不少挑戰，解釋公布之後，又引發各界批判。透過解釋學的研究與闡述，他試圖以客觀方式回應各種主觀偏好之想像。《憲法的解釋與適用》一書出版之後，一時之間洛陽紙貴，短短一年間即修訂三版⁴。後鑑於解釋學的部分較為深奧，原計畫將其抽離並單獨出版。只可惜吳氏意外早逝，此成為其未竟之業。

就邏輯上而言，「憲法解釋」不過是「法律解釋」中的一種：「法律解釋學」是「憲法解釋學」的上位概念，前者必然包含後者，後者僅是前者的一部分。然而為何在出版的時序上，吳氏先發表憲法解釋，爾後才進一步發表法律解釋學一文呢？若從〈論憲法解釋〉一文的發表時間來看，它與司法院釋字第261號解釋的公布時間相差不過一個月。除了司法院釋字第261號解釋本身極具特殊性外，在1990年上半年大法官所作之解釋中，包括司法院釋字第251號解釋（違警罰法案）、第254號解釋（國代拒絕宣誓案）、第

1 參見吳庚，論憲法解釋，法令月刊，41卷8期，頁3-6（1990年）。

2 參見吳庚，法律解釋學初探，法令月刊，44卷9期，頁3-6（1993年）。

3 參見吳庚，憲法的解釋與適用（2003年）。

4 本文以下所提及與引用該書之部分，皆源自於該書2004年6月的第3版，即吳庚，憲法的解釋與適用，3版（2004年），此亦是該書的最後一個版次。

259號解釋（直轄市組織之規範依據案）與第260號解釋（省府組織之規範依據案）等，都是與我國法治及民主轉型相關的重要案件。在當時極為動盪的政治社會環境下，這些解釋之作成，想必有諸多歧見、衝突，乃至於各種針對這些解釋的批判。吳氏於此際提出憲法解釋專文，似有回應批判、消弭衝突、化解歧見，乃至強化解釋之客觀性的企圖。

從1990年迄今已近30年，我國民主法治之建設仍處於有待強化與鞏固之階段。其間經歷不少重大爭議事件，對我國憲政民主體制之衝擊，與解嚴前後的事件相比，可謂不相上下。不論相關爭議最後是否進入憲法爭訟程序，一個憲法文本卻各說各話的情形，總是一再出現。憲法解釋學不僅不能成為定分止爭的工具，甚且成為證立分歧的基礎。這幾十年來，除了吳氏的專文與其憲法專書之外，學術界與司法實務界少有人不受限於個案、或不僅止於個案分析，而願以比較全面性的觀點來探討憲法解釋學。在此領域國內學術研究相當貧瘠的原因為何？頗值探索。比較樂觀的看法是：憲法解釋不過是法律解釋的一種，而法律解釋學已經是一門發展成熟的學科，故而不需要新的研究成果。但是就算是持此種立場，國內有關法律解釋學的出版品，在質與量上仍具嫌不足。比較悲觀的看法是：憲法解釋根本不是法律解釋，憲法本身的規範力遠不如一般法律。憲法只不過是主政者的工具，憲法解釋只不過就是主流政治勢力或學者們的偏好或說辭罷了。

試舉兩個近例說明前述情況：2016年2月1日立法院選任院長，一改過去遮遮掩掩地技術性亮票的戲碼，此次民進黨團全面大方亮票；此舉遭國民黨強力譴責。同樣的，2018年1月16日立法院進行監察委員同意權之投票，民進黨委員亦採技術性亮票。憲法對於立法院行使人事權的方式，究竟如何規定？各方說法不一。另一案例是2016年8月26日總統提名新的司法院院長，此案引起「連任」與「再任」之爭議。正反雙方都圍繞在法律解釋上，各自都找到支持

已見的論據。然而究竟何說為當？竟亦似無定論。這些見解分歧並不能以民主社會之多元見解作為支撐基礎，反而應該被視為是憲法解釋學不受重視的具體展現，甚且它們的存在會侵蝕憲法之規範權威，並戕害法治。換言之，面對重大憲法爭議，理想上不應該出現各說各話，言人人殊的景況；而是應該透過憲法解釋學的努力，進而推導出相對客觀且「正確」的結論。欲達此目的，除了一般憲法解釋方法的運用之外，尚需要憲法解釋原則的指引。

至於有哪些憲法解釋原則可以指引解釋行為，吳庚氏在其前引專著中提出四個憲法解釋原則；此對我國憲法解釋之理論發展與實務運作，貢獻匪淺。然吳氏對於憲法解釋原則的概念內涵及其所能發揮的功能，並沒有詳盡闡釋。此外，其所提之四個解釋原則係可通用於各國，但並沒有特別側重我國之憲法結構與憲法解釋實務，故尚有補充空間。以下將以吳庚教授的研究成果為基礎，先探究憲法解釋原則的概念、功能與具體內涵；後再以前引個案作說明，提出適用於我國現狀的憲法解釋原則。

貳、憲法解釋原則的概念與形式

「原則」、「準則」、「規則」、「法則」與「方法」乃不同用字，卻是詞意相近的五個常見用語。例如在〈論憲法解釋〉一文中，吳氏在介紹傳統法律解釋方法後，提出「解釋憲法特有的方法與取向」，其共包含：(1) 個別問題取向法、(2) 憲法整體解釋原則與(3) 符合憲法之法律解釋等三種特有方法或取向。爾後在〈法律解釋學初探〉一文中，將薩維尼(E. von Savigny)所提之文理的、邏輯(論理)的、歷史的及體系的等四種解釋方法稱為解釋法律的準則，並援引柯影(Helmut Coing)的著作，提出六項解釋法律的法則，它們包括：(1) 客觀性法則、(2) 單一性法則、(3) 起源論的

解釋、(4) 事物關聯法則、(5) 比較法則與(6) 假設的檢驗等六項法則。到了《憲法的解釋與適用》一書中，吳氏先提出「具有實用性之憲法暨法律解釋規則」，它們包括以下項解釋規則：(1) 解釋規則的運用有時可能因不同性質之法律而有所差別、(2) 一切解釋均從文本的字義開始(文義解釋)、(3) 歷史解釋、(4) 體系解釋、(5) 目的論解釋、(6) 意義關聯解釋、(7) 比較解釋、(8) 個別問題解決方法之解釋等八種解釋規則。後再以「專用於憲法解釋的規則」為章節標題，提出四種憲法解釋的專用規則，它們包括：(1) 以憲法解釋憲法、(2) 政治問題不予解釋、(3) 合憲性解釋與(4) 符合法律的憲法解釋等。

從「方法」、「取向」、「準則」、「法則」到「規則」，這些不同詞彙是否有不同指涉與不同內涵？即便吳氏對於這些詞彙都嘗試加註德文並予以說明⁵，但除德文之外，其他語言也有相近概念與用語；各語言之間的相近用語是否即具相同內涵？顯仍有進一步探究的必要。

一、概念

若依中文的通常用法及語義學的分析方式，前述不同的詞彙可以分成三種類型：第一種僅具單純的認知性質(cognitive)，它是人對客觀世界的理解或認識，它僅是主體意識的觀察作用，原則上不具主觀意志，「規則」或「定律」屬於這一類型，例如「物質不滅定律」或「能量守恆定律」。第二種是從單純的觀察進一步到運用人的智力去分析與歸納各種現象或生活經驗，進而提出推測、預期或指示性質(indicative)的詞語，這類詞語加上了主體意識的分析與歸納能力，「法則」、「定則」或「鐵則」屬於這種類型；典型的例子如「二八法則」、「弗萊明左手定則」或「寡頭鐵則」。第三

⁵ 如在《憲法的解釋與適用》一書中，原則(Prinzipien)、方法(Methoden)、準則(Kanon)、規則(Kriterien)，參見吳庚(註4)，頁566、465、500。

種則具有指導性質或命令性質(directive)，有清楚的主觀意志與期待，希望影響他人之行為，「原則」與「準則」屬於此種類型。如果進一步細分「原則」與「準則」之差異，前者具抽象普遍性質，後者可以說是前者的具體化。以大家熟知的「比例原則」來說⁶，目的正當、手段與目的成比例與侵害最小等三個所謂的「次原則」，其實也可稱其為比例原則的「操作準則」。

前述各類詞彙被廣泛運用於自然科學與人文社會科學，但因所涉領域不同，其意義也可能因而不同。事實上，若進一步從「規制效力」或「拘束力」的角度來看，吾人很難指稱某種自然界之規則或定律具有拘束力。蓋「拘束力」概念涉及兩個主體之意志的相互關係，而自然界之物質或現象並不具有自主之意識與意志。以此作為區分前述不同用語的基礎，「規則」或「定律」若用於自然科學領域，其僅具「認知性質」；一旦把「規則」或「定律」用於人文社會科學領域，它就可能被賦予規制力，因而改變原來僅具「認知性質」的特性，轉而變成具指導或命令性質的詞彙。至於「法則」、「定則」或「鐵則」則通用於自然科學與人文社會科學領域，它們用於指示、推測或預期，但並不具規制效力。最後「原則」與「準則」通常用於人文社會科學領域，其核心意涵乃指人之言行舉止或行動的依據，目的在影響人之行為模式或決策方向，具有指導或命令的性質，通常對人之言行具有一定程度的規制效力。

我國現行法將「規則」、「準則」與「原則」皆納為法律用語⁷，並賦予它們規制力。若以規制力的強弱程度作為區分標準，依中文習慣與我國現行法的使用情形，吾人可以說「規則」的拘束力最強，「原則」的拘束力最弱，而「準則」則介於二者之間。之所以如此，主要是因為「規制內容」的詳盡程度不同所致。通常

6 請參見我國行政程序法第7條的規範方式。

7 如中央法規標準法第3條及行政程序法第4條到第10條等。

「原則」所蘊含的規制內容最為抽象寬泛，對被規範者留有比較大的作為空間。例如行政程序法第5條至第10條規範各個不同的行政法上之一般法律原則，其具體內容仍有待透過個案實踐後，方能理解之。反之，「規則」與「準則」皆是中央法規標準法第3條有關命令的名稱，其所乘載的規制內容相對較為詳盡，對被規制之對象而言，其所擁有之作為空間也就相對狹小許多。實務上，「規則」的規制內容還略比「準則」的內容更為細膩且詳盡⁸。

回到人文社會科學場域，特別是法學領域，所謂「指導」與「命令」的意思，也就是具有一定規制力的意思，此乃是所有法規範本身所蘊含的基本特質，也是吾人嘗試理解及區別前述各個不同詞彙的基礎。基於中文習慣與法學用語實務，本文將「原則」定位為位階最高，最具簡潔與抽象特性，得以引導行為方向與決定策略的「指導」或「命令」。在「原則」之下，不論是「規則」、「準則」、「法則」或是「方法」、「取向」與「技術」，它們或可被視為是一種「次原則」或「下位原則」；或是更具體地說，它們是在「原則」之下的具體操作方法。換言之，本文對於「解釋原則」與「解釋方法」採取二者應予以區分的態度⁹，其區分方法除了基於前述語義學與我國現行法律用語的慣行之外，還包含規制力之有無。簡單地說，「解釋方法」本身不具規制力，而是實踐解釋行為的程序與手段；但是在何種情境之下應該採取何種解釋方法或是應該側重何種解釋方法？即屬「解釋原則」的範疇，其應具有一定的規制

8 依照「法規及行政規則格式撰寫原則」中的第1點有關法規名稱的部分，「規則」乃規定「應行遵守或應行照辦之事項」，而「準則」則是規定「作為之準據、範式或程序」。

9 吳庚氏對於「憲法解釋原則」與「憲法解釋方法」二者究竟有無不同？在其著作中有相當詳盡的討論。學界對於二者應否區分，以及要如何區分，見解十分分歧。吳氏傾向於將由詮釋學所衍生的各種古典或非古典的解釋規則稱為「方法」，至於像「有懷疑即作有利自由」之基本權解釋規則，或是「政治問題不予解釋」與「合憲性解釋原則」等，則稱之為「解釋原則」。參見，吳庚（註4），頁566-567。

效果。這就宛如一般民航機都設有自動駕駛與手動駕駛兩種駕駛方法，但是在何種情境應選擇何種駕駛方法？則屬駕駛原則或駕駛準則。若未依照駕駛原則選擇適當的駕駛方法，即屬誤用駕駛方法，十分容易釀成空難。換言之，解釋原則本身並不是諸多可行方法中的一種方法，而是指導方法的選擇與運用。

綜上，所謂「憲法解釋原則」可以定義為：針對憲法解釋行為之具一定規範效力的最高指導與誡命。

二、形式與類型

如果將「憲法解釋原則」理解成如何理解憲法與解釋憲法的最高指導與誡命，它將會與「憲法原則」或「憲法基本原則」的概念相互交錯¹⁰。故有學者主張：「憲法結構上的原則，就是憲法解釋的原則」¹¹，或是：「對憲法的實質理解，應以憲法原則為範疇」¹²。這種將「憲法原則」與「憲法解釋原則」等同視之的見解，固然言之成理，但二者可能存在的差異，亦不能予以忽視。事實上，「憲法原則」側重憲法的結構面與組織面，追溯憲法的起源與設計理念；「憲法解釋原則」則側重憲法的功能面與結果面，強調憲法的目的與效力。但不論二者如何存有差異，二者的確是相互交錯，關係密切。基此，每一部憲法，就像每一部法典一樣，都有它自己的基本原則。同樣的，每一部憲法，就像每一部法律一樣，也都有它自己的解釋原則。這些解釋原則可以透過不同的分類指標

10 「憲法原則」與「憲法基本原則」似應為兩個不同的概念，就語意上而言，二者的差異似應在於後者比前者在數量上更為稀少，在重要性上則更為重要。不過基於憲法本身已是一個法體系內的最高位階規範，不宜在「憲法」之上再建構一個二階的「憲法原則」與「憲法基本原則」。這種三階層（憲法、憲法原則、憲法基本原則）的建構，徒增適用上的困擾，並無實益。故本文以下將「憲法原則」與「憲法基本原則」視為相同的概念，其乃「憲法所蘊含的具有本質意義之原理或法則」。引自吳庚（註4），頁17。

11 此為H. Schäffer的說法，引自吳庚（註4），頁25。

12 此為N. Wimmer的說法，引自吳庚（註4），頁25。

來理解並描繪。

（一）以法源作區分

從法源的觀點來看，解釋原則可能來自成文法，也可能來自不成文法。特定法典或法體系以成文的方式自行規範解釋原則的情形十分常見。例如在國際法體系中，1969年的維也納條約法公約，對於條約要如何解釋，提出具體的操作方式，可以說是一種成文法化的解釋原則與解釋方法¹³。同樣的，像歐盟這樣一個特殊的國際性組織，建構歐盟法體系的相關條約也對於歐盟法體系內的法規範應

13 1969年5月23日維也納條約法公約第31條到第33條揭示解釋原則與解釋方法：

第31條 解釋之通則

- 一、條約應依其用語按其上下文並參照條約之目的及宗旨所具有之通常意義，善意解釋之。
- 二、就解釋條約而言，上下文除指連同弁言及附件在內之約文外，並應包括：
 - （甲）全體當事國間因締結條約所訂與條約有關之任何協定；
 - （乙）一個以上當事國因締結條約所訂並經其他當事國接受為條約有關文書之任何文書。
- 三、應與上下文一併考慮者尚有：
 - （甲）當事國嗣後所訂關於條約之解釋或其規定之適用之任何協定；
 - （乙）嗣後在條約適用方面確定各當事國對條約解釋之協定之任何慣例；
 - （丙）適用於當事國間關係之任何有關國際法規則。
- 四、倘經確定當事國有此原意，條約用語應使其具有特殊意義。

第32條 解釋之補充資料

為證實由適用第三十一條所得之意義起見，或遇依第三十一條作解釋而：

- （甲）意義仍屬不明或難解；或
- （乙）所獲結果顯屬荒謬或不合理時，為確定其意義起見，得使用解釋之補充資料，包括條約之準備工作及締約之情況在內。

第33條 以兩種以上文字認證之條約之解釋

- 一、條約約文經以兩種以上文字認證為準者，除依條約之規定或當事國之協議遇意義分歧時應以某種約文為根據外，每種文字之約文應同一作準。
- 二、以認證為準文字以外之他種文字作成之條約譯本，僅於條約有此規定或當事國有此協議時，始得視為作準約文。
- 三、條約用語推定在各作準約文內意義相同。
- 四、除依第一項應以某種約文為根據之情形外，倘比較作準約文後發現意義有差別而非適用第三十一條及第三十二條所能消除時，應採用顧及條約目的及宗旨之最能調和各約文之意義。

如何解釋，以成文法的方式規範於條約之中。歐盟條約第6條揭示有關歐洲基本權利憲章的法律地位，以及該憲章所提及之權利、自由與原則等事項的解釋依據¹⁴。而歐盟基本權利憲章第七章的章名就是「憲章之解釋與適用通則」，其中包含憲章第51條到第54條等四個條文，明白規定此基本權利憲章之解釋原則與解釋方法。不過，在西方民主法治國的成文憲法中，直接規範解釋原則與解釋方法的情形幾乎不曾見過；比較多的情形是揭櫫憲法基本原則或基本價值，並以此作為解釋憲法的指引。例外的情形如盧森堡憲法第48條規定必須依法進行法律解釋，而紐西蘭早自1924就有法律解釋法(Interpretation Act)¹⁵，明白規定各種法律解釋方法。南非共和國1996年憲法第39條則是有關人權清單的解釋方法，其要求法官在解釋人權問題時，必須參照國際法及外國法¹⁶。

至於不成文的憲法解釋原則，有的可能來自判例或習慣，有的可能來自學說，有的可能來自一般法律原則。例如查士丁尼法典留下不少法律解釋之原則，基本上都可以適用於憲法解釋¹⁷。再以我

14 歐盟條約第6條第1點第2段規定：「(歐洲基本權利) 憲章所揭櫫的權利、自由與原則之解釋，必須符合憲章第七章有關憲章之解釋與適用的通則規定，而且必須將憲章條款中，為闡明規範來源而所附之條文說明，仔細嚴謹地納入解釋與適用之考量中。」

15 現行法為1999年8月3日的Interpretation Act 1999。

16 其內容如下：(1) When interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal or forum—(a) must promote the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom; (b) must consider international law; and (c) may consider foreign law. (2) When interpreting any legislation, and when developing the common law or customary law, every court, tribunal or forum must promote the spirit, purport and objects of the Bill of Rights. (3) The Bill of Rights does not deny the existence of any other rights or freedoms that are recognized or conferred by common law, customary law or legislation, to the extent that they are consistent with the Bill. See S. AFR. CONST., 1996, § 39 (Interpretation of Bill of Rights).

17 試舉幾個相關的解釋原則：D. 1, 3, 23: 「在只會有一個明確的解釋時，當然就不應該改變解釋的觀點」(We should certainly not change points which have always had a single definite interpretation.); D. 1, 3, 24: 「作成判決或表示意見時，僅僅基於法規的特定部分，而不參考其整體，這並不符合專業法律人的習

國為例，司法院大法官在司法院釋字第499號解釋首次在解釋中提出憲法基本原則的概念，並列舉了幾項我國憲法的基本原則，諸如民主共和國原則、國民主權原則、人民權利保障與權力分立原則等，既是我國憲法所賴以存立之基礎，也是理解我國憲法的重要指引，它們可以說是一種來自判例的憲法解釋原則。

（二）以性質作區分

若以憲法解釋原則本身的屬性或性質來區分，此就如對一般法律解釋的理解一樣，可以分成主觀主義、客觀主義與混合論等三種基本類型。如前所述，憲法解釋原則乃是針對憲法解釋行為的最高導引與誠命，故解釋原則既是解釋行為的依據或準則，同時也是解釋行為的框架與界限；彼此密不可分，實可融合成一體。基此，探究解釋原則之屬性其實也就是探究解釋行為之屬性。而西方法學傳統對於法律解釋行為的理解，向來有主觀主義與客觀主義的區別。這種區別與法學發展的社經環境息息相關，也與法學理論的變遷互為表裏。對於法律解釋行為的屬性界定，第一種立場可稱之為「認識論」、「原意論」或「意圖論」；第二種立場則可稱之為「意思論」、「意志論」或「決定論」，第三種立場則在一定程度上融合前

慣」(It is not lawyer-like practice to give judgment or to state an opinion on the basis of one particular part of a statute without regard to the whole)；D. 1, 3, 17:「認識法律，並非拘泥於其文字，而在乎理解其力量與趨勢」(Knowing law is not a matter of sticking to their words, but a matter of grasping their force and tendency.)；D. 1, 3, 19:「於法律規定涵義不明時，應優先採取能避免荒謬結果的解釋；特別是當藉此能同時確保法律規定的目的時。」(When there is an ambiguity in an statute, that sense is to be preferred which avoids an absurdity, especially when by this method the intendment of the act is also secured.)；D. 1, 3, 29:「若有人作了法律不想任何人去作、卻未明文禁止的事，這就是規避法律。『文字』及其『意義』的區分，正是區分了對法律的規避及其抵觸」(Fraud on the statute is practiced when one does what the statute does not wish anyone to do yet it has failed expressly to prohibit. And what separates “words from meaning” separates cheating from what is done contrary to law.) 以上引自林更盛，論法律解釋的目標，高大法學論叢，7卷2期，頁6-7（2012年）。

述二者之特徵，可稱之為「統一論」或「混合論」¹⁸。這些立場的不同是建立在對「解釋行為」本身的理解而來：「解釋」行為究竟是「指出」(indiquer)還是「確定」(déterminer)某項客體(文字、舉動或事物)的意義？若是前者，則其前提要件是相信被解釋的客體本身已蘊含特定意義，它可以經由大腦意識活動而予以認識或認知。放到法學框架裡，其意指包括憲法及法律等所有法律條文，在條文陳述中已經蘊涵一定的規範意思，因此對於「認識論者」或是「意圖論者」，所謂解釋行為，就是解釋者發掘、發現條文陳述中已經蘊涵之規範意義的意識活動或認知行為¹⁹。若是後者，則認為凡是未經有權機關具體適用之前，任何法律條文都不具任何意義，或是都富含著多重意義。故對「意思論者」或「決定論者」而言，法律解釋行為就是由解釋者確定或決定被解釋法規範之意義的意思行為。

認識論的主張本侷限於文本或文字，但是事先存在的法條或文本很難解決所有社會生活可能發生的各類事物。為了補充、調整或修正條文文本本身的僵固與侷限，透過立法過程資料去探究或找尋立法者之原意或原始企圖以作為法律解釋的依據²⁰，遂成為認識論

18 有關「統一論」或「混合論」的中文介紹，特別是德國法上有關法律解釋理論的發展沿革，可參閱林更盛(註17)，頁23-27。

19 此乃吾人一般所熟知的法律解釋意義，以「文本」作為其核心概念。如吳庚氏先介紹史萊爾馬赫(Friedrich Schleiermacher)的詮釋學係以「理解」為中心，而理解則又以「原著文本」(Text)為基礎。後再引介加達默(Hans-Georg Gadamer)的詮釋理論，強調解釋法律與講解福音十分神似，皆以「文本」為中心。參見吳庚(註4)，頁439、440、454以下。又如林子儀氏援引美國學者之論著亦謂：「所謂憲法解釋(constitutional interpretation)，是用來『發現』憲法文本(Text)規定中所已存在的意義之一種適用法律的過程。憲法文本經由憲法解釋可轉化成為一些法義(doctrines)、公式(formulas)、或判斷準繩(tests)等，以用來處理特定的具體事實。」引自林子儀，憲政體制問題釋憲方法之應用——美國聯邦最高法院審理權力分立案件之解釋方法，司法院大法官九十年學術研討會，司法院主辦，頁20(2001年10月13日)。

20 例如在1927年3月11日的一個德國判決(R. Ger. Str. Bd. 61, S. 242 ff.)，就是以「立法者意思」為基礎。當時德國的法律禁止以人之意志所決定的人工流產行為，一位醫生因孕母生命垂危，為救其性命而拿掉胎兒，因而觸犯禁止人工流

的延伸發展。因而認識論與立法者之原意或立法者之企圖相結合，成為以立法者主觀之意志或原始企圖為導引，並透過分析條文結構與文字意義等方法，組構而成的法律解釋行為²¹。就此而言，薩維尼所提出的文理的、邏輯（論理）的、歷史的和體系的等四種傳統解釋方法或準則，可以說是認識論解釋方法的傳統代表。認識論者將法律體系視為是一個封閉且完整的系統，並特別強調立法者與司法者的權力分立。對法官而言，法律或是法典就是一切；解釋法律或是法典之行為，不應存有任何自由或恣意之創造空間²²。

反對認識論者認為：認識論是一種封閉且靜態的系統，就算運用各種立法資料與語意分析方法作為補充或修正文本本身的侷限，仍然不能滿足變動快速的實際社會需求。例如一個法律條文規定：「任何車輛皆不得進入公園」。一旦條文如此規定，又沒有留下任何例外空間，則必然導致窒礙難行。所謂「任何車輛」的法律解釋，

產的德國刑法第54條。法院在判決中以刑法規定中之殺人罪的處罰遠比墮胎罪更重的規範情況，進而推導出「孕母生命比胎兒生命更重要」乃「立法者之意思」，故判處此醫生無罪。參見PERELMAN (C.), *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, 2^e éd., Paris, Dalloz, 1999, pp. 52-53.

21 美國憲法解釋學有所謂的「原意主義」(Originalism)與文本主義(Textualism)，乃是以憲法文本與制憲者之意思或制憲時之公眾意圖作為解釋的基礎。其中最具代表性的人物是任職近三十年的聯邦最高法院法官Antonin Scalia，相關中文介紹可參見林超駿，美國法上有關原意主義辯論之例示與啟示——以Scalia大法官之見解為中心，收於：超越繼受之憲法學——理想與現實，頁123-185（2006年）；林超駿，Scalia大法官之憲法解釋觀——原意主義者之回應與展望，憲政時代，28卷2期，頁79-98（2002年）；比較新的介紹如陳弘儒，美國憲法解釋理論的新發展——新原意主義的方法論與中立化主張，第11屆「憲法解釋之理論與實務」學術研討會，中央研究院法律學研究所主辦，頁4-5（2017年11月14日）。該文援引Lawrence Solum的著作，將原意主義的核心命題概述如下（陳弘儒，同本註，頁7參照）：（1）憲法文本之語意，在每個規定被起草與批准時即已固著下來（語意固著命題）、（2）憲法之意義乃由制憲當時公開所理解之詞句、片語、文法與句法所決定，而非起草者之意圖（公共意義命題）、（3）憲法文本的原始意義具有法之效力，文本就是法（文本拘束命題）、（4）憲法實踐包含憲法解釋，其目的在找出文本的語意意義；以及憲法建構，其目的在確認文本的法律效果（解釋與建構區分命題）。

22 PERELMAN (C.), (註20), pp. 23-24.

包不包括幼兒乘坐的嬰兒車？打掃與清運公園廢棄物的掃葉車與垃圾車？欲進入公園救人的救護車？乃至於為了紀念戰爭勝利而放置於公園草坪中間的坦克車²³？由此可見法律解釋不可能僅依賴文本，就算再輔以立法資料也不足以解決所有可能發生的問題。故法律解釋行為應該不要完全受到文本與立法原始意圖之侷限，而應認清法律解釋的目的就是要將「人之舉止置於法規範的指引支配之下」(Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules)²⁴，是以應從文本與立法資料推衍出符合實際社會需求的法之精神、法之價值，乃至於由解釋者主觀意志所推導出的立法者之客觀企圖或意思。這種法律解釋觀方能使法律體系變成一個開放且動態的系統，並以解釋者主觀意志所作之選擇與決定，針對特定文本給定或賦予特定規範意義。換言之，對於意思論或決定論者而言，法律解釋行為不是單純的認知行為，而是一種具有補充與續造的創造行為。

凱爾生(Hans Kelsen)在其《純粹法學理論》中所談的法律解釋，就將解釋行為區分成認知行為及意思(志)行為等兩部分。他認為所謂的法律解釋，就是先透過認知行為指出條文所蘊含的意義範圍，至於在各種可能的意義範圍內選擇其中某一項意義作為解釋的結果，則純屬意思行為²⁵；而此意思行為即非屬純粹法學所能探究之客體²⁶。換言之，認識論者儘量追求客觀性，他們認為所有法

23 此例子乃源自Hart與Fuller的一段對話(H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, 71 HARV. L. REV. 593, 593-629 (1958); Lon L. Fuller, *Positivism and Fidelity to Law, A Reply to Professor Hart*, 71 HARV. L. REV. 630, 630-72 (1958))，引自PERELMAN(C.)，(註20)，pp. 53-54。

24 LON L. FULLER, *THE MORALITY OF LAW* 96 (1964)。

25 KELSEN(H.)，*Théorie pure du droit*，tr. EISENMANN(C.)，Paris, Dalloz, 1962, p. 457。

26 凱爾生認為在各種可能的規範意義中作選擇，並無科學上的方法得以運用，以選出所謂「正確」的解釋。換言之，任何一種法條意義的選擇，都可被視為是「正確」的解釋。

規範都有明確的制定主體，所有條文陳述也都有客觀的意涵，解釋者只是在既定的範圍內發現早已存在的真義，他們並未透過解釋行為積極介入或參與立法行為。至於所謂的「意思論者」則認為：規範意義並不存在於條文陳述中，在未解釋或未適用前，條文僅是紙上的線條、圖形或符號而已，沒有蘊涵特定意義，或可能包含無限意義。而解釋行為本身就是選擇、創造規範意義的意思行為。透過解釋者的意思決定，條文陳述方被賦予特定的規範意義。在此概念下，條文文字與該文字陳述所承載的規範意義是不同的兩件事，在未被解釋或被適用前，條文是客觀存在但並無特定的規範意義。如同純粹法學理論一般，「唯實解釋理論」(théorie réaliste de l'interprétation)²⁷將解釋行為視為是意思行為，並將之建構成比純粹法學理論更完整的解釋體系。

不論對解釋行為是採何種立場，前述兩派說法皆各有其不可否認的價值。事實上，此兩種論述對於解釋行為之分析都有其特定貢獻；二者雖各有其側重面向，但整合以觀，則更有助於對解釋行為的全盤理解。更重要的是：特定立場的選擇或強調，其實都是要讓解釋結果更具說服力，讓被解釋的法規範能夠發揮其實質規制力。整合前述兩派立場而成的「混合論」或「統一論」，其實就是兼顧兩家之長，一方面承認法律解釋乃以認知或認識條文為基礎，另一方面也承認條文意義的最終確定必定經過意志作用，經過選擇而作

²⁷ 唯實解釋理論的主張可以化約為以下四點：(1) 法律解釋即是賦予條文特定規範意義的行為、(2) 法律體系中存在的「有效解釋」，係指所有其他解釋皆須臣服於其下的解釋，即便該解釋不符條文字義或違背規範制定者之原意，但只要無其他解釋得以推翻之，該解釋即是「有效解釋」、(3) 此類解釋乃屬意思行為，而非認知行為，故無真偽可言、(4) 在解釋之前，條文並無特定規範意義；而規範意義是源自於解釋者，而非條文之制定者。站在意思論之立場，「唯實解釋理論」高度懷疑「法律解釋學」可以是一種科學。其主要的學者及著作如下：參見TROPER (M.), *Pour une théorie juridique de l'Etat*, Paris, PUF, 1994; TROPER (M.), *La Théorie du droit, le droit, l'Etat*, Paris, PUF, 2001; CAYLA (O.), *La Notion de signification en droit*, Thèse de Paris II, 1992; CAYLA (O.), *Le Coup d'Etat de droit, Le Débat*, 1998, n° 100, pp. 108 et ss.

出決定。吳庚氏在介紹貝提的法律解釋理論時也特別指出：法律解釋受主觀及客觀兩項因素所支配，也就是「立法者原意」與「法律原意」兩相對立的觀點²⁸；在解釋方法上，持前者觀點者特別著重文義解釋與歷史解釋，而後者則側重論理解釋、體系解釋與目的論解釋等解釋方法。在憲法解釋原則之中，有些是以認識論為基礎，例如「以憲法解釋憲法」或「政治問題不予解釋」，此二原則皆以憲法文本為基礎：前者強調必須找到解釋相應的憲法條文，如司法院釋字第499號解釋所提出的「自由民主憲政秩序」，其實是來自於憲法增修條文第5條第5項；後者則是以找不到相應的憲法條文，作為無法解釋的理由，如司法院釋字第328號解釋有關「固有疆域」的範圍，因我國憲法對於疆域範圍不以具體條文文字，採列舉界定方式，故僅能劃入政治問題範疇而無法解釋。有些解釋原則則來自於意志論，如「合憲解釋原則」，又稱符合憲法的法律解釋，其操作方法就是在諸多可能的解釋中，透過選擇而作出解釋，自屬意思論的一環。

參、憲法解釋原則之效力與功能

若吾人主張在每一部成文憲法裏都存在憲法解釋原則，它們就是解釋憲法行為的最高指導與誠命。則在此項主張之下，必然是認定憲法解釋原則有其制度功能，並能發揮一定的規範效力。

一、效力

若將憲法解釋原則視為是憲法解釋行為的最高指導與誠命，理論上而言，它本身就是一種法規範；而就像所有法規範一樣，憲法

²⁸ 吳庚（註4），頁469。

解釋原則自當具有法之效力，得以拘束解釋者之解釋行為²⁹。問題在於如何能夠將憲法解釋原則視為一種法規範？它們如何能夠拘束解釋者之解釋行為？

（一）指引說

成文憲法作為一種客觀的存在，任何人都可以對憲法文本進行解釋。本文所談的「憲法解釋者」，固然可以包括任何一個想要解釋憲法的人；但是若從法規範的角度來看，本文的終極關懷是針對憲法的「有權解釋者」，他們就是我國的司法院大法官、歐陸的憲法法院法官或是終審法院法官。不過在法官之外，憲法也可能賦予其他權力部門解釋權。在此情況下，他們當然也在「有權解釋者」的概念範圍裡。

憲法解釋者在遂行憲法解釋行為時，必然要用到解釋方法與解釋原則，只是通常這些方法與原則不會被明確地陳述或說明。舉例來說，有關地方議會正副議長之選舉方式的司法院釋字第769號解釋，在其解釋理由書第7段如此闡述：

29 於此必須強調所謂「具有法之效力」乃指具有法律上之強制力或拘束力，但不必然因之即確保每個解釋者皆必受其拘束；因為任何在法律體系上係屬合法有效的法規範，在實際上都有被違反或牴觸的可能。而解釋原則固然應該拘束解釋者，但當解釋者違反解釋原則時，在法律上並無具體制裁機制；此係大法官作為最終有權解釋者，制度上必然衍生的結果。更何況違反解釋原則的違反情狀，程度有別，並不能不論違反情節之輕重程度，一律將其解釋結果視為違憲。基於最終有權解釋者在制度上不受任何法律制裁，且其違法解釋（unconstitutional/illegal interpretation）結果也無法在法律上被認定為因違法違憲而無效，故兩位論文審查人對於本文採取解釋原則應具規範效力的立場，都持保留態度。固然最終解釋者在制度上僅能自律，其解釋內容在法律上也永遠是合法有效，但本文仍認為解釋原則具規範效力的立場，主要從「節制權力」的角度切入，並將解釋原則與憲法做高度連結，使解釋原則成為憲法文本的一部分；於此在理論上得以扣緊西方立憲主義。詳細說明請參見下文規範說的部分。

憲法增修條文第9條第1項第3款明定「縣設縣議會」，解釋上並非僅指縣議會之設立，尚得包括與縣議會組織及其運作有關之重要事項。縣議會置議長及副議長以及其選舉及罷免之投票方式，因攸關縣議員行使投票之法定職權，以選舉產生對外代表該地方立法機關，對內綜理及主持議會立法事務之適當人選，或以罷免使其喪失資格，屬與縣議會組織及其運作有關之重要事項，是中央自得以法律規範之。就此憲法授權事項之立法，涉及地方制度之政策形成，本院應予尊重，原則上採寬鬆標準予以審查。

同號解釋之解釋理由書第11段則謂：

憲法第129條明定：「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」查憲法本文及其增修條文均無明定地方議會議長及副議長之選舉及罷免事項，是縣（市）議會議長及副議長之選舉及罷免，非憲法第129條所規範，系爭規定有關記名投票規定之部分，自不生違背憲法第129條之問題。

在這同一號解釋的兩段解釋理由書中，前一段強調「縣設縣議會」之憲法條文，在解釋上當然包含縣議會之組織與運作等重要事項。但在後一段又說憲法對於縣議會正副議長之選罷並無明文規定，故議長選舉不是憲法所規定之選舉。問題是制憲者提及縣議會時，究竟有沒有想到正副議長的產生方式？為什麼「縣設縣議會」所當然包含之縣議會正副議長選舉，不是憲法第129條「本憲法所規定之各種選舉」？大法官是用什麼解釋方法與解釋原則得出「縣議會正副議長選舉不是憲法第129條的選舉」？以及「縣議會正副議長選舉非屬自治事項，得由中央立法統一規範之」？

從此號解釋各種意見紛陳可以看出大法官對於解釋方法的選用，各有不同。但是解釋方法與解釋原則的選用難道是解釋者的自由裁量空間，每個人的解釋都可以言之成理嗎？有不少人認為：除了法所明定的情形外，所有法律解釋方法與解釋原則應該只是一種參考、建議與指引，並不能對解釋者發生任何規範效力。對於意思論者來說，既然解釋本身就是一種創造行為，解釋者當然可自由運用其方法。即使是在認識論的框架之下，儘管他們認為法律條文（文本）的規範意義乃在解釋行為啟動之前即已存在，解釋行為僅是找出事前已存在之規範意義而已。但是各種法律解釋方法與解釋原則不過是輔助解釋行為的工具，可任由解釋者自行選擇運用，並不能拘束解釋者。故對認識論而言，拘束解釋者的是文本，而非解釋方法或解釋原則。最後，不論是採取認識論還是意思論，都不能逃脫一個核心的命題：「如果解釋原則本身就是一種法規範，則該規範本身（即解釋原則）也需要被解釋。」在此核心命題之下，解釋者似乎永遠擁有自由的裁量空間；解釋原則對於解釋者而言，至多只能是一種參考、指引與建議而已。

（二）規範說

把解釋原則視為是一種參考與指引，雖然留給解釋者自由創造空間，但卻造成解釋的結果歧異，各說各話，沒有真偽對錯可言。對於文學或藝術創作作品來說，這種多元的解釋結果不僅沒有壞處，可能反而還有好處，因為留下各種可能的想像空間，反而讓作品本身更具生命力。對於各級法院言，各種多元解釋也可刺激法院間的對話，讓法律爭議的思考與討論更加豐富深化。但在審級救濟制度與終審法院統一法律見解的制度下，多元終究會歸於一元；各種歧異解釋所可能產生的負面效應，最終也會透過統一見解而化於無形。然而，對於憲法的有權解釋來說，如果此「有權解釋」本身也無真偽對錯可言，是言人人殊多元並陳，而其權威完全取決於解釋者的地位，而無須慮及解釋之具體內容，則此種結果必然不利於

憲政主義與法治國理念之鞏固與茁壯；因為僅由有權解釋者決定一切的情形，無異於寡頭統治。換言之，如果多元論最後導致不論憲法規定什麼，也不論大法官說了什麼內容——只要大法官多數意見說的就是對的，就是合法合憲的，這樣的立論是絕對無法被接受的³⁰。為避免得到「大法官多數意見就是對的，就是合法合憲的」危險結果，必須存有檢驗機制來檢驗憲法解釋行為的程序過程與其具體內容。基此，除了解釋程序必須受到外在的程序規範予以規制之外，也必須存有引導憲法解釋行為的憲法解釋原則。憲法解釋原則必須成為規制憲法解釋行為的法規範，使憲法解釋行為不是純粹自由意志的運作結果，而應受到法規範所拘束；其主要理由如下：

先從立憲主義精神與法治國理念來說，所有國家權力部門的行為都應該受到法的節制與拘束；成文憲法存在的核心目的就是要限制國家權力。既然憲法有權解釋者乃是國家權力部門的一環，更重要的是「憲法之解釋行為」就是其權力內容，則不僅是「解釋者」作為國家權力機關的一部分，且「解釋權」本身也是國家權力的一環，此項國家權力自然應該受到憲法的節制與拘束。雖然憲法文本通常並不會明確規範解釋原則與解釋方法，但從整體憲法規範中仍可抽繹出憲法的基本價值與核心精神，它們即是憲法解釋原則的來源。

再從憲法作為一種以「文字」為中介的「文本」角度來看，從用字、語法、句構，到章節安排與全文的組織架構與體系邏輯，形塑了憲法文本本身的規範意義，使憲法成為一種具一定封閉性質的文本，並不容許完全自由與恣意地詮釋。這就如同演奏家的自由度

³⁰ 在接受「國會至上原則」的憲政體制下，如英國，的確可以不論國會行為之內容，只論是否是「國會所為之行為」即已足矣。但是其國會（至少下院）議員乃由人民所選舉產生，至少還有民主正當性基礎，而且也可透過選舉予以課責。除非憲法之「有權解釋者」乃經由人民選舉產生，否則其解釋行為就該受到一定的規範拘束與控制。

與創造性必然被禁錮在作曲家透過諸如譜號、音符、節拍與時值等各類記號所形成的作品框架之內。更詳細地說，有權解釋者之解釋權的大小與範圍，取決於「文本」的規範結構與授權內容。從法律詮釋學的觀點來分析，人類面對文本的智力運作方式包含三個層次：「闡明」（*expliquer; explain*）、「理解」（*comprendre; comprehend*）與「適用」（*appliquer; apply*）。對解釋者而言，在「闡明」階段，因受限於文本，自由度最小；但在「適用」階段，因脫離抽象文本而有涵攝過程，自由度最大；至於在「理解」階段的自由度，則介於二者之間³¹。但即使是在自由度最大的「適用」階段，因受到案件事實與案件背景脈絡的限制，解釋者的自由空間仍然受到限制。換言之，從法律詮釋學的角度來看，解釋者的自由是一種「被文本框限的有限自由」，憲法解釋原則正是針對解釋者是否逸脫其框限、逾越其權限的檢驗工具。

最後再從憲法作為一種規範性文件的角度來看，憲法文本必然蘊含特定規範內容，以期發生特定規範效果。例如我國憲法第50條之規範內容所預期的規範效果就是：「總統任期到了之後，無論如何都必須解職。」任何解釋內容讓總統得以在任滿日後仍不解職者，都應視為違憲；否則這個條文就沒有存在的必要。基此，不論是將憲法視為一種政治宣示而非規範性文件，或是透過解釋架空此條文的規範效果，都使憲法失去其應有之規範效力。如果憲法不再是一種規範性文件，則憲法已與文學作品無異，它如何被解釋根本無關宏旨，無須被討論。換言之，憲法作為一種規範性文件，必須拘束包括憲法解釋權在內的所有國家權力。

31 RICOEUR (P.), Le problème de la liberté de l'interprète en herméneutique générale et en herméneutique juridique, in AMSELEK (P.), *Interprétation et droit*, Bruxelles, Emile Bruylant, 1995, pp. 177-178.

綜上，憲法解釋原則乃是蘊含於憲法文本之中的憲法規範，它們與所有憲法條文一樣，都是以規範國家權力為目的。其存在目的就是要節制憲法解釋權，使該權成為一種能被預測且能被檢驗的國家權力。而整個法律解釋學的科學化發展，其目的就是要讓法律解釋結果可以被客觀地檢驗與評價；欲達此目的，指導並規範解釋行為的憲法解釋原則，不能不具規範效力。

二、功能

承前述，為使憲法能夠成為一個規範性文件，憲法解釋行為不僅需要被規範，而且還必須可以被檢驗。在此基礎之上，憲法解釋方法，以及引導憲法解釋方法的憲法解釋原則不僅必須存在，而且其存在必然能發揮特定功能。

(一) 界定權限功能

在權力分立原則所導引的憲法架構下，各個權力部門有其自己的權限範圍。包括釋憲權在內的司法機關亦屬權力部門之一，自亦有其權力界限。特別是從法律解釋理論的觀點來看，不論是採認識論或是採意思論，這兩種立場都不得不承認解釋行為本身具有一定程度的創造性格，只是創造空間的大小不同而已。對認識論者而言，解釋行為的創造性至少存在於填補法律漏洞之際；而意思論者則更是從頭到尾都認為解釋行為本身就是一種創造規範的行為。

對於解釋行為本身即是創造行為的想法在法國大革命時期十分盛行，1804年拿破崙民法典第4條明定：「凡是以法律沈默不語、模糊不清或規範不足等藉口拒絕審判的法官，將以觸犯拒絕正義之罪而追訴之。」³²此規定包含兩層意義：一是法律是一個完整且完美

³² 該條文迄今仍是有效條文，且未曾更動，亦即此處即為現行法國民法第4條的中文翻譯，其法文原文為：«Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de

的封閉系統，立法者透過理性審議所制定的法律，就是人民意志的最高展現，它只要被適用就好，根本不用解釋。一是解釋行為本身就是創造行為，解釋法律形同制定法律，法官透過解釋行為會侵奪立法者之權限。法國大革命後所建置的法院體系中，即便是終審法院本身也沒有解釋權，它僅能給下級法院適用法律的指導，但不能解釋法律。遇有法律真有適用上之困難，則僅能尋求立法者解決，由立法者自己去作解釋。

在「解釋行為」很容易或很可能轉變成「立法行為」的情況下，憲法解釋原則得以引導並劃下解釋行為的界限，闡明法官與法律二者之相互關係，並界定法官的角色，以免解釋者變成立法者，進而破壞了權力分立制度。吳庚氏將「政治問題不予解釋」列為憲法解釋原則之一，此與美國法上的「政治問題」理論相仿。而司法院釋字第328號解釋中對於我國領土疆界如何認定的問題，大法官也稱其為「重大之政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關予以解釋。」

（二）啟發與指引功能

法律解釋方法眾多，對於同一個疑義，採取不同的解釋方法，就會產生不同的解釋結果，於此會有眾說紛紜、各說各話的缺點，讓人民一方面無所適從，同時也不能信服司法權威。

雖然西方法解釋理論與實務長期發展以來，已經建立了基本解釋原則。一般而言，法律解釋行為所採取之解釋方法，其優先順序如下：文字與語言學之解釋方法應最優先使用，再來是體系與邏輯解釋方法，最後才是目的論解釋途徑。除了前述三種解釋途徑的優先順位外，另有不少常見的一般法律原則與西方法諺被用於解釋之中。這些一般法律原則與法諺作為解釋原則或方法，有時不免也會

與前述三種解釋途徑相衝突，如此也會造成解釋結果的歧異。

憲法解釋原則存在的一項重要功能正是要指引解釋行為，特別是解釋方法的選用，以期消弭可能發生的解釋結果歧異，或甚至是衝突。就積極面而言，憲法解釋原則存在的目的或功能，其實也就包含了憲法解釋行為存在的目的或功能，就是要以「最能實現憲法規範」為目的，亦即要讓憲法不是單純文字而已，而是能成為真正能發揮規範效力的法典。在此積極面向下，憲法本身的規範目的就成為憲法解釋所不可或缺的組成要素。例如西方立憲主義精神下的憲法規範目的，無疑就是要透過節制國家權力的方式，來確保人民權利免於遭致侵害。基此，任何憲法解釋的方式導致國家公權力或行使公權力之個體得以逸脫憲法之桎梏或拘束，而可以自由行使權力的結果，都是屬於不可被接受的憲法解釋。

就消極面向而言，憲法解釋原則存在的目的，至少要能排除解釋憲法竟產生荒謬的結果。至於何種結果是屬於荒謬的結果？此亦要以憲法規範目的作為最重要的判斷基準。

（三）論證、說服與正當化功能

法律解釋工作並不僅是為了產出一個特定的解釋結果而已，更重要的是此解釋結果必須令人能夠接受，令人願意對其臣服。欲達此目的，解釋者必須詳細說明其獲得特定解釋結果的步驟與方法，其推理邏輯與心證證成過程。

特別是憲法爭議涉及國家最高規範與國家公權力運作之實際衝突，直接涉及憲政穩定與憲政發展，影響層面極大；故而憲法解釋工作遠比一般法律解釋工作更需要詳細論證與努力說服，以化解各種可能的猜疑與挑戰。

作為解釋方法之指引的憲法解釋原則，不僅可以引導解釋者找到正確的解釋方法，同時更可在解釋結果中作為解釋論證與說理的

一部分。更重要的是：因為此論證與說理的努力，往往可以強化解釋結果本身的正當性。以今日西方國家之憲法解釋工作者的產生方式來看，他們幾乎都不是經過人民選舉產生，所以美國學者稱其面臨「反多數」或「抗多數」之困境。雖然沒有民主正當性基礎，但只要解釋本身是經過充分說理與論證，他們至少還有「專業正當性」可以補強其常常被批判的「民主赤字」。

肆、憲法解釋原則之內涵

在探求憲法解釋原則有何具體內涵之前，必須先處理兩個前提問題。一是憲法解釋與法律解釋究竟有無不同？其答案就決定了在一般法律解釋原則之外，是否還有憲法解釋原則存在的空間？設若憲法解釋原則的確有獨自存在的空間，則下一個問題就是要問：憲法解釋原則是否具有普遍性？是各國憲法架構下有各國特有的憲法解釋原則？還是大致相近的憲法解釋原則其實是可以適用於不同國家之憲法解釋？

一、憲法解釋原則具特殊性？

憲法解釋原則本身具有其特殊性，與一般法律解釋原則有所不同，故應該予以明確區別的想法，學界討論甚豐³³。此種區別的主要立論基礎，除了因憲法之規範特質不同於一般法律之外，尚有憲法規範對象的特殊性。

（一）基於憲法條文之規範特質

憲法作為一個國家的最高位階規範，必然是一份極為抽象簡潔的法律文件。基此，不論抽象性或是簡潔性，都給憲法文本留下很

³³ 詳見吳庚（註4），頁557-566。

大的解釋空間；因為抽象容易形成模糊，而簡潔則會留下疏漏。而模糊與疏漏所留下的解釋空間，絕對不僅止於「認知」而已，更多的情況是讓解釋者享有相對寬廣的「創造」空間。

對於憲法條文具有抽象性與簡潔性的特質，吳庚教授援引 Ronald Dworkin 與 Robert Alexy 的著作，詳細闡明 Dworkin 所提出之「原則」(principle) 與「法規」(rule) 兩個不同的概念³⁴：具「原則性格」的法規範，它不僅是概括或抽象，而且其規範內容在法律上及事實上有多种實現可能，在此情形下，原則不外是作出最佳選擇之要求或是誡命。至於「法規」則較具體確定，在適用時，僅有符合或不符合兩種選項，別無其他選擇。一般而言，憲法條文多屬原則性規定，常常沒有任何具「法規」性質的具體內容，所以常是一種不完整的法規範，其適用特別有賴解釋。例如我國憲法第11條規定：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」這樣的規範方式明顯沒有任何具「法規」性質之規範內容，而僅是「原則」之揭示。吳氏進一步指出：如果遭遇「原則」衝突，例如新聞自由與國家安全，或是法律保留與大學自治，則一定要由解釋機關來化解衝突。故「憲法院或是釋憲機關的功能，就是將不完整法規範或純粹的原則模式，使其完整化或是使其兼具法規的規範效力」。³⁵

其次，再從法規範之適用程序來看，涵攝過程是形成結論的必要步驟。但是基於憲法條文多屬不完整規範，通常沒有可供涵攝的構成要件內容，因此也就無法經由演繹過程而涵攝事實關係³⁶。更

34 詳見吳庚（註4），頁568-572。

35 引自吳庚（註4），頁571。

36 引自吳庚（註4），頁575。論文審查人於此指出：其實某些憲法條文，例如人權條款，還是有其構成要件內容，故可以作為涵攝的基礎。而德國憲法釋義學的確開展出「基本權利的構成要件」，或是「基本權利的保障範圍」等概念，進一步去具體化人權條款。但是不論是基本權之構成要件或是基本權之保障範圍，它們都不是憲法已經明文予以規定的內容，而是透過憲法解釋才產生的結果。且看司法院釋字第414號解釋（吳庚、蘇俊雄及城仲模大法官）部分不同意見書（節錄）如此闡述：「憲法關於人民基本權利之規定通常僅為原則

何況在抽象審查模式下，法院檢視不同法規範間的相互關係，僅重視法規範位階秩序，常常與事實無涉。基此，一般審判案件所使用的傳統三段論，在憲法爭訟中即未必能完全適用。

最後，憲法條文所使用的文字及語法如果過於專業化與技術化，對一般人民而言，這種憲法就會是一部人民對之既無法理解也無法產生感情的無字天書。所以作為最高法規範的憲法，若與其他一般法律相比，卻很矛盾地使用最白話，最簡明易懂的庶民語彙，基本上不會具太多專業性與技術性用語。但是憲法條文所要規制的

(Prinzip)之宣示，而欠缺具體之規制(Regel)，此種情形以我國憲法最為顯著，現行憲法第二章第10條以次，均祇宣稱人民有何種權利，至於各該權利之範圍為何？其涵蓋之構成事項究何所指？概付闕如。對於如何確定各個基本權之保障範圍，在基本權理論上素有廣義說及狹義說之分。廣義說主張就憲法基本權條款所宣示之原則，依概念分析之結果，其所涵蓋之構成事項，皆屬於各該基本權之保障範圍，至於發生具體之基本權事件是否與受保障之構成事實相當，換言之，法律對此等基本權事件所為之限制合憲與否，應從相關法益均衡保障之觀點，予以判斷，亦即運用比例原則審查其合憲性。狹義說則謂憲法基本權條款之保障範圍，應先將憲法上與之相對立之原則或依照一般法律原則所保障之客體排除後，所留存之構成事項，始屬各該基本權實際之保障範圍。舉例言之，維護公共利益與保障個人言論自由乃憲法上相對立之原則，而國防機密之保護為公共利益之一環，若依狹義說，洩漏國防機密即不在言論自由之保障範圍。……關於基本權之保障範圍，德國優勢之學說係採廣義說，實務上亦未將商業廣告排除於基本法第5條意見自由保障範圍之外（參照聯邦憲法法院之案例BVerfGE 30, 336, 352.）。蓋推銷產品或勞務之廣告固屬追求經濟上利潤為目的，但並不因此而謂廣告非意見之一種，保障經濟事務領域意見之表達及形成，與其他事務之領域並無軒輊，尤其將經濟上之意見與意識形態嚴加以區別，為事實所難能，故不應存在差別之待遇。……本院受理此類案件，一向以限制人民權利之法規是否違背憲法保障人民權利之意旨，尤其是是否符合憲法第23條之法律保留原則及比例原則為衡量標準，並未以聲請案件所述之事項不在憲法第二章某一條規定之列，將其摒除於相關權利保障範圍之外，從而認為法規自得任意予以限制，此種釋憲方法，顯屬前述之廣義說。新近公布之釋字第407號解釋，亦僅認定主管機關對出版品記載如何始構成猥褻之釋示尚未達違憲程度，而非謂猥褻之出版品不屬憲法第11條之保障範圍，便是相當於廣義說之一種運用。本件多數通過之解釋遵循本院一貫之立場，不採所謂商業廣告或藥物廣告非屬言論自由保障範圍之主張，自應予以支持。蓋此種詮釋方法不僅符合我國憲法之理論體系，抑且解除戒嚴為時未久，人民基本權利之保障猶待加強，若採狹義說以除外方式，將若干行為排除在該當權利的保障範圍之外，此例一開，後果不堪設想。」

對象，絕對不會比一般法律所欲規制之對象更為單純簡化，有時反而是更加複雜難解。在此情況下，憲法解釋以及引導憲法解釋的憲法解釋原則，不僅有存在之必要，而且其在內容上不同於一般法律解釋，更在重要性上遠勝於一般法律解釋。

（二）基於憲法規範對象之特性

西方立憲主義憲法所要規範的對象，就是整部國家機器之運作，就是國家公權力之行使；更精確地說，就是參與及掌控國家權力運作的人。在此概念下，執政者以及執政之政治勢力，未來可能取得執政權的反對黨，以及運作國家機器的公職人員，他們都是憲法所要規範的核心對象。換言之，憲法對他們而言，絕對不是一種得以鞏固權力或是擴張權力的工具，反而是一個節制權力與限縮權力的枷鎖。這也就是為什麼憲政主義與法治主義愈不成熟穩固的國家，執政者常於批判憲法，更有熱衷於修改憲法，以期解除其權力枷鎖的傾向。

既然憲法通常是站在主要政治行動者與政治參與者的對立面，更是執政者永恆的緊箍咒，他們自然總是會想方設法地擺脫憲法的拘束。更重要的是這些人不僅是憲法所要規範的主要對象而已，他們常常還是憲法的直接適用者與解釋者；這與一般法律的規範情形截然不同。以交通法規而言，被規範的對象是人民，但是直接適用法規的人是警察；被規範對象（人民）既無適用權，也無解釋權。反之，例如總統或立法院，既是憲法規範的對象，同時也是直接適用相關憲法規範的人。他們自己適用憲法，自己解釋憲法，自然會朝向有利自己的解釋。在此情況下，為確保憲法持續是一份規範性文件，有權解釋機關的憲法解釋就顯得格外重要。

事實上，憲法，以及以規範國家機關為目的的其他公法法規，形成一個控制國家機器並節制國家權力的「規範整體」³⁷，它們不同於以人民為主要規範對象的其他一般法律。這個由憲法領銜的「規範整體」都面臨其規範對象既是規範的直接適用者，同時也是解釋者的問題。更有甚者，不同於一般法律之適用者與解釋者的中立地位，憲法以及其下之公法「規範整體」與其適用者與解釋者常常處於一種敵對關係。此「敵對關係」使憲法解釋不同於一般法律解釋，除了傳統法律解釋方法的運用之外，憲法解釋更需要其他的解釋原則指引，以化解此敵對宿命所可能產生的解釋謬誤。

二、憲法解釋原則具個別性？

作為憲法解釋方法的指引或誠命，憲法解釋原則是否是一種普遍性與一般性之原則，適用於每一個國家的憲法解釋工作？理論上而言，解釋方法與解釋原則應該是一種客觀存在的操作步驟或運作工具，不因解釋對象的不同而有不同。但是這樣的想法至少存有兩個問題：一是把解釋對象（文本）與解釋方法完全切割是不可能的，因為解釋方法中的三種基本途徑，包括文字、語言學與語意學

³⁷ 憲法文本究竟為何？在概念上素有「形式意義的憲法」與「實質意義的憲法」之分。（參見吳庚、陳淳文，憲法理論與政府體制，增訂6版，頁1-3（2019年））究竟哪些法規應置入憲法法典內？各國的規範情形各有不同。但不論憲法文本的規範方式為何？某些具本質重要性的法規，就算不被列入憲法法典內，也不能將其視為與一般性法律無異。以我國法為例，例如個別憲法機關的組織法（如法院組織法、中央行政機關組織基準法）與運作法（司法院大法官審理案件法/憲法訴訟法（預定於2023年施行）、立法院職權行使法、監察法），地方制度法，預算法與財政收支劃分法及公職人員選舉罷免法等，不一而足。這些法律雖僅有法律位階，但其重要性高於一般法律，具有「準憲法」之性質。至於其他規範行政機關的行政法規，如行政程序法或政府資訊公開法，雖然不具憲法位階，也不必然具有準憲法之性質，但這些行政法規仍是在節制國家權力與控制國家機器的規範精神與脈絡之下，故可將之視為一個「規範整體」。

之解釋方法，體系與邏輯解釋方法，以及目的論之解釋途徑，它們都與文本密不可分。僅以最具客觀性的文字、語言學與語意學之解釋方法來說，它們就是以文字與語言為基礎；而每一種文字的特質與語法不同，其解釋方法很難一體適用。更不用說體系與邏輯等解釋方法，更受限於文本所形構的體系與其所蘊含的自有邏輯，不容易採用一體適用的解釋方法。第二個問題是：就算解釋方法是一種客觀的獨立存在，可能與解釋對象相互切割。但是基於解釋方法與解釋原則二者之間存有交疊流動關係，也會導致解釋原則可能稀釋解釋方法的客觀純度。更詳細地說，解釋原則其實是如何選用解釋方法的指引或命令，它必然要慮及解釋對象所處之脈絡，進而才能成為良善且適切的解釋指引或命令。更詳細地說，解釋對象之脈絡形塑解釋原則，進而造了解釋原則的個別性或特殊性；而此解釋脈絡至少包含以下三個重要面向：

（一）制度

憲法文本規範國家機關之組織與國家機關間之權力互動關係，本身就足以形成特定制度；而這些不同制度組成了憲法的基本結構。例如有關我國現行憲法所規範的政府體制類型，不論是從文本本身，還是依當時制定過程的史料來看，無疑是最接近法國式的半總統制。但是在此半總統制下，尚有我國特有的一院制國會與監察及考試兩權。事實上，憲法既定制度甚多，從中央政府體制、地方自治制度、國家緊急權到違憲審查制度等，不一而足。而正是從這些憲法所形塑的不同制度，彰顯各國憲法的共通性與獨特性。例如權力分立原則是西方立憲主義憲法所共通共有的基本原則，但是在此原則之下，基於政府體制的不同，也會形成「剛性的權力分立」與「柔性的權力分立」等兩種邏輯不同的權力分立原則³⁸。因為制度的設計理念不同，對其憲政實務運作的解讀邏輯即應不同。

38 詳見吳庚、陳淳文（註37），頁413-416。

（二）情境

任何法規範存在的目的都是為了要具體適用於特定情境，若將情境因素抽離，法規範甚至沒有辦法產生任何規範意義。即使抽象法規審查與一般法律在個案中之適用仍有所不同，但是抽象法規範仍有其自有的規範情境。例如國會要通過一個反恐法案，法案中對於恐怖份子嫌疑犯之通訊自由與人身自由保障，採取低於一般人的保障標準。即便是在事前抽象審查階段，亦即該法案根本還沒有生效施行，該法案仍有其自有規範情境：包括是否有恐攻事件已發生或受到威脅，國際反恐規範的一般標準與規範變遷，本國反恐能力，以及恐攻事件或威脅對社會所造成的傷害或可能傷害等。

事實上，法規範通常是長時間地持續存在；特別是憲法，其更有永恆存在的預想。一旦發生法律適用及法律解釋問題時，必然是在特定時點，在特定的時空環境背景下；此特定時點下的情境因素自然會影響並決定法律的適用與解釋方法。這也就是為什麼傳統法律解釋方法中，對於歷史解釋的使用時機，會特別適合適用於開始施行生效時間較淺短的法規範，因為其立法情境與執法情境背景相當。

（三）價值

固然西方立憲主義以限制國家權力並保障人民權利的基本精神普見於各國憲法，但在此共同價值之外，各國仍有因其自有憲政文化與經濟社會情況而蘊含或發展出自己所特有的憲法價值。這些憲法自有之價值，也可稱之為「憲法特質」³⁹。例如加拿大是一個聯邦體制國家，本身因其多族群特性，特別強調「共同體」的概念。加拿大聯邦最高法院在處理聯邦與邦之權限衝突問題時，開展出「核心及本質原則」(pith and substance)、「跨管轄豁免原則」(the

39 吳庚（註4），頁576。

interjurisdictional immunity doctrine) 及「聯邦至上原則」(the paramounty doctrine) 等三個基本原則⁴⁰。德國基於二戰期間納粹政權侵害人權的慘痛歷史經驗，特別重視基本權保障，民主原則與對行政權之限制。而在德國與歐盟的互動過程中，德國聯邦憲法法院特別提出「德國憲法認同」的概念，作為捍衛德國憲法的工具。所謂德國憲法認同就是德國基本法第79條第3項所規定的核心原則⁴¹。法國第五共和憲法為矯正過去政府更迭頻繁，行政權柔弱不振的積習，則特別重視國會權力的限制與行政權之維護。法國憲法委員會在其面對歐盟法與歐盟法院時，也會強調「法國的憲法認同」⁴²。事實上，近年來在歐盟整合過程中，特別重視各會員國之本國「憲法認同」。在歐盟條約第4條第2款的明確援引下⁴³，「憲法認同」概念成為近年歐洲憲法學界的流行議題⁴⁴。至於美國法則不能忘記其制憲先賢念茲在茲的聯邦主義與共和主義，以及因種族問題而特別重視的平等權等。這些憲政價值除了受到制憲先賢的思想

40 詳見吳庚、陳淳文（註37），頁420-423。

41 這些核心原則是連修憲權都不得觸碰的德國憲法基本原則，它們包括聯邦體制、各邦共同參與聯邦之立法、人性尊嚴之保障、社會國條款、法治國原則、民主原則與抵抗權等。詳見2009年德國聯邦憲法法院有關里斯本條約的裁判（BverfGE, 2 BvE 2/08, § 208, § 210, § 211, § 217, § 228），相關內容可再見於新近裁判，如德國聯邦憲法院2015年12月15日有關歐洲逮捕令的裁判BverfGE, 2 BvR 2735/14, § 41, § 75, § 84-3, BverfGE 123, 26.

42 法國憲法委員會在2006年7月26日的案例（CC 26 juillet 2006, n° 2006-540 DC, Rec., p. 88）中首次使用此概念。詳見ROUSSEAU (D.), *L'identité constitutionnelle, bouclier de l'identité nationale ou branche de l'étoile européenne*, in BURGORGUE-LARSEN (L.), *L'identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe*, Paris, Pedone, 2011, p. 89.

43 該條文的內容如下：「歐盟尊重各會員國在條約之前的平等地位，並尊重各會員國基於其憲法與基本政治結構，以及地方及區域自主所固有的國家認同。歐盟尊重各會員國的核心國家功能，特別是確保國家領土完整，維繫公共秩序，以及保衛國家安全；其中尤以國家安全事項為各會員國之專屬職權。」See Consolidated version of the Treaty on European Union Art. 4, Oct. 26. 2012, 2012 O.J. (C 326/1).

44 MILLET (F-X.), *L'Union européenne et l'identité constitutionnelle des Etats membres*, Paris, LGDJ, 2013, p. 365.

與理念之影響，以及憲法所設計之制度的引導外，也透過後來的憲政實踐逐步形塑而成。

綜上，每一個國家基於其制憲歷史，憲法本身所呈現的制度設計，經濟社會文化發展背景，以及行憲以來所累積的憲政實務運作經驗等，逐步形塑其憲法意識與憲法價值，進而能彰顯其憲法之特色與風格。用於引導憲法解釋工作的憲法解釋原則，受到其所欲解釋憲法之脈絡、特色與風格的影響，在一定程度上也會展現其個別性⁴⁵。

三、憲法解釋原則之具體內容

既然每個國家的憲法都有自己的憲法解釋原則，中華民國憲法的憲法解釋原則為何？而這些原則又從何而來？

先就來源而言，如前所述，無疑是從制憲史，憲法文本與歷年憲法解釋所推導演繹而來。在憲法施行之初，制憲先賢之思想與社會情境背景主導解釋原則之發展。反之，隨著憲法實踐經驗愈來愈豐富，歷年憲法解釋所一再闡明或強調的內容，也就逐步形成新的憲法解釋原則。換言之，憲法解釋原則不是一個僵固的概念，而是一個動態的生命體；只是其演化過程格外緩慢，要經過歲月的洗鍊，才能逐漸沈澱出新的解釋原則。

45 例如美國學者Philip Bobbitt在他的書中提到historical（歷史的）、textual（文本的）、doctrinal（學理的）、prudential or practical（務實的）、ethical（社會道德的）、structural（結構的）等六種美國憲法裁判之論證方法，而對於ethical論證方法，他如此闡述：“By ethical argument I mean constitutional argument whose force relies on a characterization of American institution and the role within them of the American people. It is the character, or *ethos*, of the American polity that is advanced in ethical argument as the source from which particular decisions derive.”轉引自PHILIP BOBBITT, CONSTITUTIONAL FATE: THEORY OF THE CONSTITUTION 94 (1982).

再就憲法解釋原則的具體內容而言，吳庚氏在其大作特別歸納出四個專用於憲法解釋的規則⁴⁶，它們應該可以說是共通於各國的憲法解釋原則。但在此四個原則之外，尚可由我國憲法文本與憲政經驗中找到四個具我國特色的憲法解釋原則。

(一) 通用原則

吳氏所提四個專用於憲法解釋的規則，此處「專用」二字的意思是與法律解釋做區隔，意思就是僅用於憲法解釋的解釋原則。吳氏並未指出這些專用原則或規則是否為我國所獨有，反而在說明中廣泛援引各國憲法解釋案例，以呈現此四原則具有通用性與普遍性，適用於各國之憲法解釋活動；其內容概述如下：

1. 以憲法解釋憲法

憲法作為最高規範，不僅使其成為法體系內所有其他法規範的基礎，同時也是理解這些法規範的最高指引。同樣的，想要理解憲法與解釋憲法，自然也要優先以憲法文本作為參考基準。吳庚氏強調以憲法解釋憲法包括三層意義⁴⁷，第一是要重視「憲法特質」，第二是要維繫憲法本身的自主性與體系性，最後則是不能破壞憲法的整體性。

2. 政治問題不予解釋

政治問題理論是美國法上發展出來的著名釋憲法則，類似的想法或實務操作經驗，也見諸於其他歐陸國家⁴⁸。我國大法官在司法院釋字第328號解釋首次援引此概念，其具體內容在司法院釋字第387號解釋吳庚大法官的不同意見書中有比較詳盡的說明。爾後的

46 詳見，吳庚（註4），頁576-598。

47 吳氏並以司法院釋字第499、520及546號解釋等三號解釋闡釋此原則，詳見吳庚（註4），頁576-580。

48 詳見吳庚（註4），頁581-583。

解釋中對此概念討論最多的是司法院釋字第632號解釋，該解釋中對於是否應援引此概念，意見頗為分歧。事實上，此原則的適用困難在於如何界定「政治問題」？美國法在*Baker v. Carr*一案⁴⁹中由Brennan大法官所提出的六項判準究竟能否持續適用？能否移植至我國？不乏有質疑之聲⁵⁰。

雖然連美國自己都已很少使用此概念，我國釋憲實務援引此概念的情況亦十分有限，但其作為憲法解釋原則之一，仍有其必要。因為在實際憲法爭訟中，法院總有不受理或受理後無法在實體上給予決斷的案件，問題只在此類案件要如何表述而已。「政治問題」作為一種表述理由，其實與德國法上「功能最適」的描述差距不大，都是界定司法權範圍的一種表述。不過就表面字義而言，「政治問題」顯然要比「功能最適」更加淺白易懂，或許這也是我國大

49 See *Baker v. Carr*, 369 U.S. 186 (1962).

50 如許宗力，*憲法與政治*，收於：《憲法與法治國行政》，頁39-46（1999年）。在司法院釋字第632號解釋許宗力、廖義男兩位大法官的協同意見書中，對政治問題理論如此表述：「本院先前解釋曾採取所謂『政治問題原則』，亦即基於權力分立之考量，司法者對於憲法賦予政治部門（包括行政及立法部門）作政治裁量之事項，應尊重其判斷，不得逕以司法裁決取代之（本院釋字第四一九號解釋理由書參照）。但學界對於司法者得否任意訴諸『政治問題』，作為司法消極或不予審查之理由，毋寧抱持著較為審慎之態度，率多認為政治問題原則並非司法者所能輕易援用。且憲法問題或多或少具有政治性，卻非司法者不適合介入之政治問題；只要案件涉及『憲法議題』，尤其是政治部門之行止已牴觸憲法秩序時，司法者即不得因案件具有高度政治性，即畏縮地躲避到政治問題原則的保護傘下。本件立法院程序委員會以程序杯葛的方式，確實引起輿論在政治上的高度關注，牽動立法院各黨團間及總統與立法院間之敏感神經；本席等也同意，程序委員會暫緩將一般議案編列議程，乃常見之政治抵制手段，具有釋放特定政治訊息、形成特定政治議題之功能，從良性的角度而言，可促進更廣泛之政治參與及討論，有助於形成更周全的政策或解決方案，本院原則上應無置喙之餘地。問題是，本件所涉及的是一個『憲法機關』（監察院）之存續與否，以及一個憲法機關（立法院）是否忠誠地行使其『憲法義務』（憲法增修條文第七條第二項之人事同意權）；尤有甚者，該憲法義務之不履行，已導致另一憲法機關人事空懸長達二年有餘，而遭到實質凍結。此等憲法之應然規範加上時間因素，使得本件聲請案顯然涉及『憲法議題』，且無尊重政治部門（在此為立法院）判斷之空間，本院自不得托言『政治問題』而規避捍衛憲法秩序之職責。」

法官予以選用的考量理由。

至少在Brennan判準中的「憲法明定由政治部門處理」、「欠缺處理相關問題的司法基準」、「逕行作成政策決定」與「作成決定形同不尊重其他機關」等四項，仍屬可以有效操作的判準。以司法院釋字第632號解釋來說，立法院消極不行使同意權，是否即屬立法院因不履行憲法義務而違憲？以前述四項判準而言，除逕行作成政策決定外，其他三項皆可適用。大法官著眼於監察院完全無法運作的客觀事實，將導致此結果的立法院消極行為視為違憲，問題是大法官所依恃的裁判基礎為何？此乃大法官在解釋中說不清楚，也因之而飽受批判之處⁵¹。

3. 合憲性解釋

合憲性解釋原則又稱「符合憲法的法律解釋」，亦屬各國憲法訴訟實務普遍使用的原則。該原則存在的目的方面是要儘量尊重享有民主正當性基礎的國會決定，另一方面也可排除因違憲宣告而造成可能出現「法律空窗」的風險。雖然對於該原則的評價，學者間見解分歧。但是吳庚氏特別放到我國現行依然的法制不備的情境下⁵²，基於我國不是立法緩慢，就是立法草率的憲政實務，導致立法效率不彰與立法品質不佳。在此背景下，率爾宣告法律違憲不僅不能解決問題，反而可能製造更多的問題。反之，利用合憲性解釋原則，在必要時透過轉換或替代等技術，直接調整法條意義，在我國反而是更有價值的策略。

51 參見余雪明大法官在司法院釋字第632號解釋的部分不同意見書，余氏認為本案至少符合Brennan判準的前兩項。該部分不同意見書對美國法上政治問題理論有詳盡的討論，同時也指出多數意見的缺陷。另有彭鳳至及余雪明兩位大法官的不同意見書，對多數意見亦有詳細批判。

52 詳見吳庚（註4），頁585-596。

4. 符合法律的憲法解釋

這個原則看起來似有矛盾，因為常態上是以上位階規範來解釋下位階規範，豈會顛倒而行。這種憲法遷就法律的情況雖屬特殊例外狀況，但實務上仍常出現。其存在之必要性至少有以下兩種情形：一是憲法雖有授權，但卻留給立法者幾近完全自由的裁量空間。例如憲法第61條規定行政院之組織以法律定之，但對於行政院應設多少二級機關與三級機關？其權限範圍與人員如何分配？憲法未置一詞；顯然是留給立法院自由決斷。二是沒有憲法授權，完全是國會自主決定的產物。例如司法院釋字第585號解釋所涉及的「三一九槍擊事件真相調查特別委員會」，就是沒有任何憲法依據，立法者自主決定的產物。嚴格而言，這兩種情況都是涉及國會的 formed 自由，釋憲機關自當儘量尊重；但其又並不純屬「政治問題」，因國會之 formed 自由有可能侵害其他權力部門，故司法權仍有介入審查的空間。至於在尊重國會自主空間之餘，如何進行司法審查，就需要更進一步具本國憲法特色之憲法解釋原則來指引。

（二）我國特有之憲法解釋原則

前文提及，各國憲法基於「制度」、「情境」與「價值」的三重考量，可以形塑具有自我特色的憲法解釋原則。例如加拿大聯邦最高法院在處理魁北克分離問題時，就曾指出「聯邦主義」、「民主」、「法治」與「少數保障」是加拿大憲法的四個基本組成原則⁵³。而其首席大法官Brian Dickson也曾指出：「當聯邦立法或是邦立法之目的是為了促進加拿大社會中弱勢團體之利益時，法院必須以儘量順服立法部門的態度來行使其違憲審查權」⁵⁴。換言之，在

⁵³ Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217; 161 D.L.R. 4th 385; Robin Elliot, *References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of Canada's Constitution*, 80 CAN. BAR REV. 67, 72-74 (2001).

⁵⁴ Edwards Books and Art. Ltd. v. The Queen, [1986] 2 S.C.R. 713.

多元種族與分離主義的背景下，「少數與弱勢保障原則」成為加拿大憲法自有的憲法解釋原則。同樣的，我國憲法也有其自有之制度結構、情境與價值，其中結構源自於憲法文本所預設的相關制度，情境則是憲法所處之時空背景，而價值則來自於制度結構與情境的融合。在綜合考量此三個層面，本文提出以下四個我國特有的憲法解釋原則，「特有」二字係指由前述制度、情境與價值等三個層面融合而成，成為我國現行進行憲法解釋行為時，應特別側重的憲法解釋原則。

1. 立憲主義目的優先原則

西方立憲主義的核心目的就是透過憲法規範來節制國家權力，以保障人民權利。此既是憲法存在的目的與價值，也是解釋憲法必須遵守的最高指導原則。故任何解釋的結果導致國家權力擴張，國家權力無法被節制，或是人民權利遭到不當限縮與侵害，應該都是違反憲法規範意旨的解釋。

理論上，憲法條文應該可以清楚呈現憲法本身存立之目的。在此情況下，前述「以憲法解釋憲法」原則應該就會包含「立憲主義目的優先原則」。再者，此解釋原則既然是立基於立憲主義，則應該是適用於擁有立憲主義憲法的所有國家，而不該被視為是我國的特有解釋原則。然而在實際上，各國憲法本文不一定會直接明述憲法存在的核心目的，就是要節制國家權力與保障人民權利⁵⁵；比較多的情況是制憲目的出現在憲法前言，或是其他制憲時的重要文件⁵⁶。基於憲法文本未必皆清楚揭櫫立憲主義目的，故在「以憲法

55 比較晚近的憲法比較容易在憲法條文中呈現立憲主義精神，例如二戰後的德國基本法第1條有關人性尊嚴之保障，即明述行政、立法及司法等國家權力直接受此條文之拘束。

56 例如美國憲法前言及著名的聯邦論文集（THE FEDERALIST PAPERS）或是1789年法國大革命後的人權宣言。以後者為例，該宣言第16條揭櫫：「凡是權利無法被確保，權力沒有被明確分立的社會，就是沒有憲法的社會。」

解釋憲法原則」之外，「立憲主義目的優先原則」仍有存在之必要。特別是中華民國憲法前言、憲法本文及後來的增修條文，都沒有對「節制國家權力」有直接且明確之規定，尤其需要此解釋原則作為輔助。

雖然諸如「權力分立」或是「制衡」等節制國家權力的字眼，都不曾在我國的憲法文本出現過。但是大法官歷年解釋逐步將這些字眼引入解釋文中⁵⁷，確立了我國憲法為立憲主義的憲法。而正是因為我國憲法文本欠缺「分權」與「制衡」等這些節制國家權力的字眼，更使得「立憲主義目的優先原則」必須成為我國的憲法解釋原則。只是要將此原則作為一個具規範效力的憲法解釋原則，仍然必須在憲法規範上找到依據。如前所述，憲法解釋原則可能來自於成文憲法，也可能由不成文憲法形塑而成。然不成文憲法主要由憲法解釋所產生，為避免套套邏輯，必須是反覆為解釋者所肯認並引用者，才能成為憲法規範的一部分。這就如同習慣要成為法源，同時需要存在反覆慣行與司法機關之肯認。我國大法官在諸多解釋中強調中華民國憲法是一部立憲主義憲法，不僅強調權力分立，同時也保障人民權利。從過去數十年的憲法解釋內容來看，立憲主義所蘊含之分權與制衡精神已經成為我國憲法的一部分，自然可以由其推導出我國的憲法解釋原則。更何況在成文法層次上，憲法第二章明確揭示人權保障之精神，且憲法增修條文第5條第5項也明文揭示「自由民主憲政秩序」，此亦即司法院釋字第499號解釋所闡釋之我國憲法賴以存立之基礎。從節制國家權力、維護自由民主憲政秩序，到人權保障，處處皆彰顯立憲主義之精神。

2. 憲法忠誠原則

就字義上而言，「憲法忠誠」意指「忠於憲法」與「服膺憲

⁵⁷ 在解釋文中提及權力分立與制衡的相關解釋如司法院釋字第391、498、499、530、585、613、633、645及729號等解釋。

法」，我國憲法前言最後四個字「永矢咸遵」，就是指「誓言永遠遵守整部憲法」，其實也就是對憲法忠誠的意思。從立憲主義的角度來看，「守憲行憲」當然是憲法對其規範對象最基本也是最重要的誠命。就此而言，憲法解釋必須遵守憲法並忠於憲法應該也是一個適用於所有立憲主義國家的憲法解釋原則。然而，在我國卻必須將此本應視為是理所當然的事情予以強調，有以下三個理由：

(1) 我國憲政民主仍待鞏固

對於制憲行憲已經超過兩百年，民主運作相對穩定的美國來說，若有人以每一個世代應決定自己的價值為理由，質疑對憲法忠誠的必要性，並不會令人感到特別意外。因為現在仍在使用的美國憲法，絕大部分的內容都是在四輪馬車時代所決定的，其與今日世界之生活方式與時代價值必然有相當差異。故確實有美國學者以活人世代之民主運作，企圖挑戰制憲先賢所定下的古老價值與憲法規範。尤其在美國修憲程序相對困難的情況下，憲政民主應該如何緩解或鬆脫死人之手的控制問題⁵⁸，直接衝擊憲法忠誠義務的必要性。

相較於美國民主，我國民主真正開始全面正常運作，要以1990年司法院釋字第261號解釋之後開始起算，迄今不到30年。同樣的，我國憲法於二戰後制定，與多數具有成文憲法的憲政民主國家相仿，憲法文本並不算特別老舊。更何況我國也是在廢除動員戡亂時期臨時條款後，才算真正開始行憲，與西方憲政民主國家相比，我國的行憲經驗相對淺短許多。在民主與憲政都還不算穩定成熟的背景下，我國現今自然不能效法部分美國學者質疑古人拘束今人的主張；先學會對憲法忠誠，顯然才是我們鞏固民主與強化憲政政治所不可或缺的要件。

⁵⁸ 中文文獻可參見蘇彥圖，憲政民主的死人之手問題——憲法規範權威的初步反省，收於：李建良編，憲法解釋之理論與實務（九），頁141（2017年）。

（2）憲法與國家認同分歧

由於我國憲法的效力範圍，在客觀上現今僅及於憲法文本所規範之領土範圍的極小部分，導致部分人民與知識菁英對於中華民國以及中華民國憲法產生認同上的質疑。然而國家認同問題本質上是一個政治性問題，在大部分的情況下與法治無涉；例如不會因為國家認同問題而影響道路交通管理處罰條例的施行。換言之，在絕大部分的情形下，憲法之施行與運作與國家認同無關。但是在另外一方面，憲法本身就是一種規範政治權力的文件，憲法直接決定了公權力的運作範圍與行使方式。一旦執政者或政治行動者以國家認同與憲法認同為由作為擺脫憲法桎梏的藉口，特別是以「不認同憲法」來掩蓋其違憲舉措，或甚至是合理化其違憲行為，此種情況自然會對憲政民主造成重大傷害。

如前所述，憲法認同與國家認同二者其實是可分離的，因為憲法的本體不論是節制國家權力還是保障人民權利，基本上與國家認同無關。從孫文思想，三民主義到考試、監察兩院的存在，雖有某些歷史傳統上的象徵性意義，但卻在實質上與立憲主義精神並不抵觸。更何況憲法要拘束的直接對象是掌握公權力的政治菁英，而不是一般人民。以國家認同問題來質疑憲法認同的想法或話語，多出自政治行動者或知識菁英之口；而他們正是憲法所欲規範的主要對象。一旦憲法所欲規範的主要對象宣稱不認同憲法，其實他們就是想要擺脫憲法對其行止的枷鎖；而這正是立憲主義所欲遏止之事。

（3）司法權威仍待強化

如英國這般沒有成文憲法的國家，其民主運作與憲政秩序仍能穩定的理由，除了其歷史傳統、政治文化與經社情況等條件外，有一個具相當司法權威的獨立司法體系，肯定是最重要的因素之

—⁵⁹。與英國相較，我國司法體系的獨立性迄今仍十分不足，司法決定的公信力與其司法權威無法完全源自於法官本身⁶⁰，故特別依賴由憲法所移轉而來的權威。事實上，普通法的傳統的確是可以不依賴制定法，而以法官與法院本身之權威作出具司法權威之裁判。但在大陸法系傳統下，制定法則是法官裁判最重要的權威基礎。我國繼受大陸法系傳統，同時也有成文憲法，且在司法權威尚嫌薄弱的情況下，釋憲者當然必須緊抱憲法，從憲法取得其解釋權威。

綜上所述，我國現在的憲法解釋者與適用者不僅需要忠誠於憲法，而且更需要強化並強調他們對憲法的忠誠，如此一方面得以證立其解釋或適用行為之合法性與正當性，另一方面也可以強化其決定或解釋之權威性。

3. 重視比較法原則

在國際交流十分密切的全球化世界下，法律相互參照並相互影響本就不足為奇。特別是在憲法領域裡，因為立憲主義的目的與核心價值，諸如節制國家權力，保障人民權利與人性尊嚴，實踐法治主義與民主原則等涉及國家權力之運作部分，較不受個別文化的影響⁶¹，所以更有參照他國憲法與憲政運作的必要，以擴增視野並獲

⁵⁹ 參見陳淳文，法治社會之司法權威初探，收於：陳春生編，法之橋：臺灣與法國之法學交會——彭惕業教授榮退論文集，頁27-50（2016年）。

⁶⁰ 有關司法權威之可能來源的介紹，請參見陳淳文，釋憲機關的司法權威——由法國與我國違憲審查實務來看司法權威的建立，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（八）（下冊），頁385-389（2014年）。

⁶¹ 反之，例如刑法上通姦罪之存廢問題，就涉及各國文化與社會通念，比較必須考量本國情境。故大法官在司法院釋字第554號解釋理由書第3段如此表示：「以刑罰手段限制有配偶之人與第三人間之性行為自由，乃不得已之手段。然刑法所具一般預防功能，於信守夫妻忠誠義務使之成為社會生活之基本規範，進而增強人民對婚姻尊重之法意識，及維護婚姻與家庭制度之倫理價值，仍有其一定功效。立法機關就當前對夫妻忠誠義務所為評價於無違社會一般人通念，而人民遵守此項義務規範亦非不可期待之情況下，自得以刑罰手段達到預防通姦、維繫婚姻之立法目的。矧刑法就通姦罪處一年以下有期徒刑，屬刑法第六十一條規定之輕罪；同法第二百四十五條第一項規定，通姦罪為告訴乃

得更多參考資訊。更有甚者，若是兩國的憲法文本有相近的結構與制度，例如同是議會內閣制的憲法，其實二者即可說是建立在共同基礎之上。在此情況下，相互比較與參照，更是憲法解釋工作所不可或缺的一部分。然而將國際法與外國法作為憲法解釋的參考依據，在多數情況下不屬憲法明文規定的一部分，故釋憲者究竟應否參考比較法，並非沒有爭論⁶²。但是這種爭論對於新興民主法治國與繼受型憲法而言，意義相對弱化許多。反而因為援引比較法，可以在一定程度上抽離國內情境包袱而增廣視野，提供說理論據，進而強化新興民主國的憲法解釋權威。諸如東歐後共國家中的匈牙利憲法受德國基本法影響甚深，匈牙利憲法法院即大幅參照德國聯邦憲法法院之裁判⁶³。即便都是民主法治國，加拿大因地理上的關係，也深受美國憲法實務的影響⁶⁴。更不用說南非憲法第39條明定

論，使受害配偶得兼顧夫妻情誼及隱私，避免通姦罪之告訴反而造成婚姻、家庭之破裂；同條第二項並規定，經配偶縱容或宥恕者，不得告訴，對通姦罪追訴所增加訴訟要件之限制，已將通姦行為之處罰限於必要範圍，與憲法上開規定尚無牴觸。」

62 以美國為例，早在1957年就有學者對於應否使用外國法作深入討論（see Pradyumna K. Tripathi, *Foreign Precedents and Constitutional Law*, 57 COLUM. L. REV. 319, 319-47 (1957).），而近年更因Stephen Breyer與Antonin Scalia兩位大法官在Printz v. United States, 521 U.S. 898 (1997)一案中的針鋒相對，而使此問題格外受到外界關切。大法官Breyer在此案之不同意見書特別指出：「毫無疑問地，我們要解釋的憲法當然是我們自己的憲法，而不是外國憲法；而且我國憲法與外國憲法之間，必然在政治系統與結構系統上有重大差異。儘管如此，對於一個相同法律問題所提出之各種不同解決方案的後果，外國憲法實務經驗確有啟發與指引的作用。」（Of course, we are interpreting our own Constitution, not those of other nations, and there may be relevant political and structural differences between their systems and our own. Cf. The Federalist No. 20, pp. 134-138 (C. Rossiter ed. 1961) (J. Madison and A. Hamilton) (rejecting certain aspects of European federalism). But their experience may nonetheless cast an empirical light on the consequences of different solutions to a common legal problem...）另外，諸如Sandra D. O'Connor和Ruth B. Ginsburg等兩位大法官也持相近立場。參見Anne-Marie Slaughter, *A Global Community of Courts*, 44 HARV. INT'L L.J. 191, 199-200 (2003).

63 See CATHERINE DUPRÉ, *IMPORTING THE LAW IN POST-COMMUNIST TRANSITIONS* (2003).

64 Claire L'Heureux-Dube, *The Importance of Dialogue: Globalization and the International Impact of the Rehnquist Court*, 34 TULSA L. REV. 15, 16 (1998).

解釋人權問題時必須參考國際法與外國法，南非憲法法院在有關死刑的State v. Makwanyane and Another (CCT3/94) [1995] ZACC 3一案中，即同時參照了美國、加拿大、印度、德國及匈牙利等最高法院或憲法法院的裁判。

不過比較法的運用，絕不是任由解釋者得以東挑西揀，任意裁剪自由選用，而是必須完整比較，整體參照。換言之，選擇參照或比較對象，不是一個恣意行為而是一個理性行為，必須考量對象的可比較性與可參照性。例如以色列最高法院處理有關總統赦免權的爭議時，就發生應否以及能否把英王與美國總統的赦免權拿來作參照比較的問題？其最高法院長Aharon Barak認為以色列總統的憲政地位與憲政角色不同於英美元首，故不應任意參照比較，他如此強調：「比較法所能獲得的啟發，僅在有共同基礎之上才能發生；也就是在那些有共同基礎的制度、程序與觀點之上，吾人才能進行比較」⁶⁵。

吳庚教授將「比較解釋」視為是憲法解釋與法律解釋所共通的解釋規則或解釋方法⁶⁶，並指出我國之主要法律，諸如民法乃至各類行政法規，多是由德、瑞、日等各國法制移植而來，比較解釋方法遂顯得格外重要。吳氏更舉司法院釋字第265、371、509及549號解釋來說明我國釋憲實務運用比較解釋情況。其實就算不是繼受外國法制，在全球化的今日世界裡，很多事物既相似又彼此相互牽連，不少基本信念或價值也成為大家的共識，因此任何國家之釋憲

65 See HC 428/86, Barzilai v. State of Israel, 40(3) PD 505, 600 (Barak J., dissenting): "From the foundation of the State, we drew extensive interpretive inspiration from the wellsprings of American and English constitutional law. The views of those countries in many areas, like human rights, often serve as an example for us. However, we must limit the nourishment we seek from them. Inspiration can occur only if there is a common foundation. We can only compare institutions, procedures, and views that have a common basis."

66 詳見吳庚（註4），頁540-543。

者，很難完全自外於今日世界之外，自為解釋。連最不重視比較法的美國聯邦最高法院，例如當其處理能否對青少年（16-17歲）判處死刑時，也會參照比較各國法制的情形之後，再作出最後的決斷⁶⁷。

特別是在憲法領域，我國憲法不算是「原生的」憲法，而是學習與模仿西方成文憲法而來。憲法中諸如考試、監察等少數自有特色的部分，尚不足以改變憲法整體的外來性格。換言之，制憲及修憲的歷史，以及憲法結構與條文內容讓我們可以找到相似的憲法，其可作為參照比較的共同基礎。從憲法解釋原則之規範效力的角度來看，「重視比較法原則」其實可以是「原意主義」的一種變形；其規範效力就是來自於憲法文本。更詳細地說，若欲探尋我國憲法之規範意義，基於部分憲法條文的外來移植性格，以及立憲修憲過程中外國法對我國憲法之影響，我國憲法文本之原意往往需要溯源到外國法。例如，如果不知道我國1997年修憲的主要推動者及參與者的背景與想法，以及法國第五共和憲法在此次修憲過程中的影響，就不能了解我國現行憲政體制為什麼會有法式半總統制的色彩。在此大幅受外國法影響的背景下，「重視比較法原則」的憲法

67 美國聯邦最高法院以「足以標示一個成熟社會之進步的莊重標準」(standards of decency that mark the progress of a maturing society)來詮釋美國憲法增修條文第8條(eighth Amendment to the United States Constitution)有關禁止酷刑(cruel and unusual punishment)的意義。連向來對外國法之援引持保留待度的Scalia，在其意見書中的註1如此闡述：“We emphasize that it is *American* conceptions of decency that are dispositive, rejecting the contention of petitioners and their various *amici* (accepted by the dissent, *see post* at 389-390) that the sentencing practices of other countries are relevant. While [t]he practices of other nations, particularly other democracies, can be relevant to determining whether a practice uniform among our people is not merely an historical accident, but rather so ‘implicit in the concept of ordered liberty’ that it occupies a place not merely in our mores, but, text permitting, in our Constitution as well, *Thompson v. Oklahoma*, 487 U.S. 815, 868-869, n. 4 (1988) (Scalia, J., dissenting), quoting *Palko v. Connecticut*, 302 U.S. 319, 325 (1937) (Cardozo, J.), they cannot serve to establish the first Eighth Amendment prerequisite, that the practice is accepted among our people.” *See Stanford v. Kentucky*, 492 U.S. 361, 381 (1989).

規範基礎，其實與原意主義相當，就是來自於憲法條文本本身，也就是除了條文文字意義與文法結構外，還包含該條文的思想淵源、研擬與公開討論情況，以及其制定過程等。基於我國憲法條文有不少屬於「非原生」條文，比較法解釋不僅止是一種解釋方法而已，它更應該是一個我國憲法解釋所必須特別側重的解釋原則。尤其是在涉及政府體制與國家權力衝突的議題，更不應該完全沒有比較法視野。此際更應該重視比較法，並善用比較法，此不僅有助於解決我們自己的憲法難題，更可以強化憲法解釋的司法權威。

4. 結果務實原則

吳庚教授援引瑞士學者Fritz Gygi的說法：「一切解釋結果都應考量其實際可行性，否則就應改採其他解釋。⁶⁸」吳氏並進一步指出在多種解釋可能進行選擇時，至少要考量兩項因素：一是不得牴觸憲法文本與憲法基本價值，二是考量解釋能否被遵守或被執行而審慎維護司法權威。這種考量結果的解釋方法，吳氏稱其為「個別問題解決法」，並以司法院釋字第261、419、461、499及520號等解釋為例，說明此解釋方法在我國釋憲實務的運作情形。

一般法院在適用法律與解釋法律時，固然可以將此解釋原則列入考量，但沒有必要將其列為應予以優先考量的原則。其最主要理由乃在於一般法院的裁判效力僅及於個案而無通案效果，倘若個案問題並沒有在訴訟中被妥適解決，此種結果就算對當事人乃至整體社會有不利影響，其影響範圍也僅限於個案而已。反之，在憲法訴訟中所爭議的事項，或是具通案性的抽象規範（如一般法律違憲案），或是對權力運作與國家發展影響深遠的重大政治決定（如核四停建案），若不務實考量結果，其所造成的不利後果，顯然非一般個案訴訟所可比擬。

⁶⁸ 詳見吳庚（註4），頁543-550。

結果務實原則的規範基礎從何而來？如何證立其具有規範效力？我們的確很難直接在憲法條文中找到依據。不過，中華民國憲法因具社會福利主義色彩而定有基本國策專章，其中不乏涉及國家整體發展之方向與政府具體行動之方針，在解釋上不能將此章視為是憲法上完全不具規範效力的特區；因為同一部憲法內的不同條文，應該皆有相同的法律位階與相同的法律效力。但是憲法本文的基本國策與增修條文第10條的拘束力要達何種境地？則就一定要考量解釋時的特定情境，務實地作出解釋。此處「務實」的意思，除了要體認司法權應扮演之角色及權力之界線外，更要考量國家整體經濟財政能力與社會發展程度。例如司法院釋字第485號解釋特別提及因國家資源有限，立法者基於社會政策之考量制定法律，將福利資源為限定性之分配時，「必須考量國家之經濟及財政狀況，依資源有效利用之原則，注意與一般國民間之平等關係，就福利資源為妥善之分配。」簡化地說，就是國家推動福利政策時，必須平等且務實。又如憲法第153條有關勞工與農民之保護規定，司法院釋字第422號解釋謂：「以固定不變之金額標準，推計承租人之生活費用，而未斟酌承租人家庭生活之具體情形及實際所生之困窘狀況，難謂切近實際，有失合理，與憲法保護農民之意旨不符。」從這兩號解釋可以看到大法官認為不論立法權或行政權之運作，都必須務實。基於同樣理由，司法權之運作又如何能不務實？吾人可以據此進一步推演：基於基本國策與增修條文的規範內容與規範方式，我國憲法本身就蘊含憲法解釋必須務實的規範意義；此可謂係基於事物之本質，不證自明之理。工作權保障不能解釋為國家必須確保無人失業，國家推行全民健康保險也不能推導出人人得享有醫療免費的結論。憲法第164條有關教科文經費之規定，正是因為過於明確僵固，不夠務實，才被憲法增修條文第10條第10項所修正；此修憲條文本身也是憲法規範必須務實的具體展現。既然憲法規範必須務實，國家權力之運作必須務實，憲法解釋當然也必須務實。

就具體操作而言，結果務實的解釋原則至少要考量三個面向，其一是本案爭執是否能有效解決，二是所提解決方案是否會引發其他不利後果，最後則是解釋結果是否會危害司法權威。以司法院釋字第632號解釋為例，解釋作出之後的結果是：立法院對該號解釋置之不理，立法院擱置或遲延行使人事同意權的事例仍一再發生。此案例讓吾人清楚看到：忽視結果務實原則的後果就是該號解釋不僅不能解決問題，反而因解釋不被尊重而戕害大法官的司法權威。

綜上所述，本文所提出之我國特有的憲法解釋原則，其實幾無創新之處，不過就是從我國憲法文本與司法實務萃取出來，並將之與幾種一般法律解釋常用的方法相互融合，同時在考量我國現行的法治情況之後，將它們提升為「解釋原則」之地位，作為引導解釋或指示解釋方法之選用的上位階誡命；而其最主要的規範對象就是憲法的解釋者與適用者。至於這些解釋原則適用順序，其實就如一般法律解釋方法的適用情況一樣，常常是屬於綜合考量、同時併用的情況，並無絕對的優先適用順位⁶⁹。

伍、具體操作

基於前文討論之架構，以下嘗試就我國實際發生的兩個個案進行操作。雖然這兩個個案都沒有進入憲法爭訟程序，但其已經引發憲法解釋爭議乃不爭之事實，故自得以憲法解釋的觀點予以分析。

一、立法院院長選舉與人事同意權案

我國立法委員推選其正副院長時，究竟應採秘密投票方式？還是公開亮票方式？歷來爭執不斷。而各地方自治團體議會之正副議

⁶⁹ 吳庚氏曾如此表示：「憲法解釋（法律解釋亦然）很少僅使用一種方法就能獲致結論，在通常情形毋寧是方法論的混合主義。」，引自吳庚（註1），頁6。

長選舉能否亮票？也是長久以來的爭議。就政治實務而言，不論是在中央或是地方層次，我國主要的政黨或是政治勢力對於此問題都曾立場反覆：有時主張應秘密投票，有時又支持可公開亮票。對於應採秘密投票的理由，乃以「反賄選」作為主要訴求；至於應公開亮票的說法則是為讓立法委員或地方議員必須服從黨紀，以「落實政黨政治」與「彰顯責任政治」⁷⁰。

就法律上而言，除憲法文本外，包括「立法院議事規則」、「立法委員互選院長副院長辦法」、「立法委員互選院長副院長投票及開票辦法」等，都無立法院正副院長選舉須採取秘密投票之規定。倒是舊的地方制度法第44條明定議長之選舉應採無記名投票方式，但對違反者並無罰則。實務上，檢方常以刑法第132條第1項的公務員洩漏國防以外秘密罪，第147條的妨害投票秩序罪，或是第148條的妨害投票秘密罪等條文作為起訴依據。但是這些法條是否適用於議員亮票行為，大有疑問⁷¹；檢方起訴與否又標準不一，法院見解亦相互分歧。2015年9月最高法院作出104年度第14次刑事庭會議決議，其要點如下：第一，亮票行為不屬刑法第132條第1項的洩密罪；第二，現行法並無處罰亮票行為，基於罪刑法定原則，自不能以法相繩；第三，秘密投票規定是為保護投票人，但若投票人自願亮票，自願放棄此保護，與法無違；最後，亮票未必與賄選有關，在無刑法規定制裁之前，應屬議會自律事項，司法權不應介入。2016年6月22日地方制度法第44條及第46條修正通過，新法將原本

70 例如司法院釋字第769號解釋理由書第8段：「按縣議會議長及副議長之選舉及罷免，究應採記名或無記名投票方式，因各有其利弊，尚屬立法政策之選擇。查中央立法者考量地方議會議長及副議長之選舉實務，為彰顯責任政治，並防止投票賄賂行為（立法院第9屆第1會期第2次會議議案關係文書院總第1544號委員提案第18257號及第18525號參照），乃修正為系爭規定，將地方議會議長及副議長之選舉及罷免，由無記名投票改為記名投票方式，有其上述正當目的，且其手段與目的之達成間亦有合理關聯，並非恣意之決定，尚未逾越中央立法權之合理範圍。」

71 詳見吳庚、陳淳文（註37），頁716。

的秘密投票改為記名投票。司法院大法官更在2018年11月的司法院釋字第769號解釋認定：此改為記名投票之修法既不違背中央與地方之分權規定，也因議長選舉不是憲法第129條所規範之選舉，故不生違背憲法第129條之問題。

除了正副院長選舉之外，立法院尚有各項人事同意權，行使此類同意權應採秘密投票？還是公開亮票？實務亦有爭議。

（一）結構分析

承前所述，「制度」、「情境」與「價值」是構成每個案件的基本結構，應以此結構作為分析基礎：

1. 制度結構

憲法文本形成制度結構，立法院長選舉案所涉及的條文為憲法第66條、第129條、第131條及第132條。

憲法第66條規定正副院長由委員「互選之」，第129條規定「本憲法所規定之選舉」的選舉方式，第131條規定選舉之競選方式，應公開競選，第132條規定選舉應嚴禁威脅利誘。

由前述條文結構來看，核心的問題是：立法院正副院長選舉是否屬於第129條之「本憲法所規定之選舉」？單從字面上看，將第66條及第129條結合以觀，正副院長選舉當然屬於第129條所謂的「本憲法規定之選舉」。但有謂第129條所適用之對象「應為人民直接行使其主權之選舉而言」⁷²，或「憲法第12章所稱之選舉，應指憲法第17條所定，以人民為選舉人之各項選舉」⁷³，既不包括立法院正副院長之選舉，更不包括地方議會正副議長之選舉。

⁷² 司法院釋字第769號解釋黃瑞明大法官之協同意見書。

⁷³ 司法院釋字第769號解釋黃昭元大法官之協同意見書。類似見解如同號解釋許志雄大法官之協同意見書、羅昌發大法官之協同意見書。

事實上，從文義解釋到體系解釋都很難得出立法院正副院長選舉不屬「本憲法所規定之選舉」，其理由如下：

首先，如果憲法第12章僅專指人民行使選舉權而言，則包括憲法本文所明定的正副總統選舉（憲法第27條）與監察委員選舉（憲法第91條）即不受憲法第12章之拘束，難道制憲者認為像正副元首與監委等國家重要職位之選舉，可以不受第131條及第132條之拘束？

其次，若依前述見解，則憲法第129條之「除本憲法別有規定外」的字義要如何理解？憲法本文有哪一種人民行使之選舉權是屬於憲法第129條的例外規定？如果吾人不知「除本憲法別有規定」的意義內涵，就無法正確理解憲法第129條的規範意義。

再者，第129條之「本憲法所規定之選舉」就算僅限於人民行使投票權之選舉，但若依司法院釋字第769號解釋所採取的解釋方法⁷⁴，則凡是不是憲法或憲法增修條文所明定的選舉，包括直轄市市長及直轄市市議員、鄉鎮代表、鄉鎮長與村里長，都不屬「本憲法所規定之選舉」，因此也都可以不受憲法第129條之限制，而得任由立法機關自由決定其選舉方式。然則在現今六都格局已成的情況下，直轄市人口已佔我國人口總數七成以上；若依前述大法官所採之解釋方式，只要不是憲法明定的選舉，皆屬立法裁量範圍。此無

⁷⁴ 司法院釋字第769號解釋理由書第11段謂：「查憲法本文及其增修條文均無明定地方議會議長及副議長之選舉及罷免事項，是縣（市）議會議長及副議長之選舉及罷免，非憲法第129條所規範，系爭規定有關記名投票規定之部分，自不生違背憲法第129條之問題。」在此解釋中，大法官對「本憲法所規定之選舉」採取嚴格解釋的方式，將其限於憲法明文規定的選舉。依此「憲法明定」之標準，憲法第113條第1項規定省長及省議員之選舉，且規定其由選民選舉之。同樣的情形也見於憲法第124條第1項以及增修條文第9條第1項第3款規定縣議員之選舉，及憲法第126條與增修條文第9條第1項第5款規定規定縣長之選舉。反之，對於直轄市，憲法第118條僅規定直轄市自治以法律定之，但對於自治的選舉方式未置一詞。

異於賦予立法院多數黨得以自由決定直轄市市長及其議員之選舉方式，對我國之民主鞏固恐有不利影響。

最後，立法委員選舉制度經修憲改為單一選區兩票制後，國會生態與制度結構與昔日大相逕庭，此對於立法院院長的選舉方式是否造成影響？亦應予以一併考慮。

2. 情境結構

「反賄選」與「落實政黨政治與責任政治」是與本案直接相關情境。不論立法院或地方議會，究竟有否賄選事實，成為重要關鍵。以1999年的第四屆立法院院長之爭為例，劉松藩與王金平兩人同黨鬩牆激戰，賄選傳聞不絕於耳。劉落敗後再因涉及弊案潛逃出境，最後客死異鄉。至於地方議會，向來因為地方議員素質不高，甚至成為黑道漂白的場所。例如2000年時，前屏東縣議會議長因殺人罪被判死刑並於同年執行槍決，同案還有三名屏東縣議員被判無期徒刑。事實上，從地方議員到議會議長的選舉，賄選事例確實頻傳。

至於政黨政治的發展，在中央層級因立委選制改變後，政黨政治似乎逐步成形。只是我國的政黨政治是激烈對抗型的政黨政治，立法院內政黨抗爭杯葛，打鬥不斷，議事紀律蕩然無存。在此背景下，院長職位之屬性是應該更加政黨化與黨紀化？還是應該更加中立化？此外，議會內閣制與半總統制等政府體制之特色，對議長職位屬性亦有所影響。基本上，議會內閣制與半總統制是行政向立法負責，由國會多數黨組閣，且法案主要來自於行政權的政府體制；此與美國式總統制的組織與運作模式截然不同。基於其政府體制的特質，內閣制與半總統制的國會議長通常都是扮演中立公正的角色，不以政黨立場或政黨偏好來主持議事進行。至於我國地方議會，因為選舉制度仍採「複數選區單記不可讓渡制」(single non-transferable vote, SNTV)，加以地方派系的長期影響，地方議會很

難形成穩固的政黨政治體系⁷⁵。換言之，在選舉制度不改的情況下，政黨政治與黨紀在地方議會的重要性相對較低；而立法院又因政黨激烈鬥爭而特別需要一個沒有政黨立場，僅嚴格忠於議事規則、公正處理議事程序爭議與議會紀律的中立議長。

事實上，政黨政治與責任政治的概念，恆與政策相關，而不應與人事案綁在一起。除了議會正副議長應去政黨化，以扮演中立角色外，即便是諸如大法官、監察委員、考試委員與其他獨立機關的人事同意權，議員行使職權時，也都應該去除黨派思維，超越政黨立場而投票。反倒是如何促進反賄選與政治廉潔之改革，應該才是現今議會選舉的當務之急。

3. 價值結構

選舉應廉潔、公平、公開、公正乃憲法第129條、第131條及第132條明文規定的基本價值，亦屬大法官所強調之民主原則與自由民主憲政秩序的一環。所謂亮票可以反賄選，事實上僅能防止同一議員「多重收賄」，但卻降低賄選成本，並會助長憲法第132條所欲禁絕之事項⁷⁶。

至於黨紀維繫與民主課責問題，尚非憲法與我國現行議會選舉實務所必須追求的價值。大法官支持亮票係為彰顯責任政治，並防

75 以地方議員的黨籍分佈情形而言，2014年地方選舉中非兩大黨之黨籍議員共230席，國民黨籍為386席，民進黨籍為291席；2018年的地方選舉結果，非兩大黨黨籍議員共275席，國民黨有394席，民進黨有238席。就直轄市與一般縣市的比較而言，其中直轄市的兩大黨議員比例相對較高。若以單一縣市來看，例如2018年選後雲林縣議會的組成，國民黨7席，民進黨12席，無黨籍議22席，小黨2席，總計非兩大黨的議員佔55.8%。參見中選會選舉資料庫網站，<http://data.gov.tw/node/13119>（最後瀏覽日：2019年11月8日）。

76 在秘密投票的制度下，議長候選人因無法有效檢驗行賄對象的投票行為，所以可能付出較多的行賄成本，買較多的議員。而收賄的議員也可能收錢又跑票，所以過去有透過「技術性亮票」來驗收，並將行賄分成前金後謝。反之，在亮票的制度下，收賄的議員不敢「多重收賄」；且在地方惡勢力的威脅下，議員也可能被「強迫收賄」或被迫「賤價賣票」。

止投票賄賂行為的說法，除了與我國議會運作實務不符外，更隱含著亮票尚可與罷免制度掛鉤的想像。更精確地說，此背後所涉及的價值問題為：我國民意代表究竟是「自由委任」，還是「強制委任」⁷⁷？立委與議員究竟要屈從於「黨紀」與「黨意」？還是應傾聽「民意」？司法院釋字第401號解釋認為立法委員行使職權所為之言論與表決，自應對其原選區之選舉人負政治上責任。看起來亮票是為了向「選民」交代。此外，司法院釋字第499號解釋揭示我國修憲程序應公開透明，並認為我國制度不是純粹的自由委任⁷⁸；但這兩號解釋都是針對「對事」的背景下所作的解釋。至於若在議長選舉時亮票，因選民與立委或議員之間根本不會在選舉前得知何人會選上議員或立委，並將參選議長，所以二者之間對於議長人選根本沒有任何委任關係，亮票顯非為了向選民負責。在此情況下，亮票只能是為了要議員或立委臣服於黨紀，對政黨負責。但是在「對人」的投票上遵從黨意，此究竟要追求何種憲法價值⁷⁹？

77 參見吳庚、陳淳文（註37），頁570-578。

78 司法院釋字第499號解釋針對修憲（對事）程序採秘密投票一節，其與「對人」之投票顯有不同。再者，修憲行為涉及國民主權之行使，亦非立法院院長之選舉所可比擬。在該號解釋理由書第8段，大法官如此闡述：「至於相關機關以自由委任理論為其採無記名投票理由一節，按現代民主國家固多採自由委任而非強制委任，即民意代表係代表全國人民，而非選區選民所派遣，其言論表決對外不負責任，原選區之選民亦不得予以罷免，但非謂民意代表行使職權因此全然不受公意或所屬政黨之約束，況且我國憲法明定各級民意代表均得由原選舉區罷免之（憲法第一百三十三條及本院釋字第四〇一號解釋），與多數歐美國家皆有不同，就此而言，亦非純粹自由委任，從而尚不能以自由委任作為其違背議事規則之明文規定採無記名投票之正當理由。」

79 如果是為了落實「責任政治」，也應該是聚焦在政策面上（對事），而不是在「對人」的投票上。例如司法院釋字第613號解釋理由書第2段後半稱：「民主政治以責任政治為重要內涵，現代法治國家組織政府，推行政務，應直接或間接對人民負責。根據憲法增修條文第三條第二項規定，行政院應對立法院負責，此乃我國憲法基於責任政治原理所為之制度性設計。是憲法第五十三條所揭示之行政一體，其意旨亦在使所有行政院掌理之行政事務，因接受行政院院長之指揮監督，而得經由行政院對立法院負責之途徑，落實對人民負責之憲法要求。」大法官過去所謂的「責任政治」係行政向立法負責，以達「對人民負責」的憲法要求。而也正是在此基礎之上，憲法增修條文第3條第2項第3款才會規定對行政院長提出不信任案，須以記名投票表決之。

（二）解釋操作

由前述三層次的結構分析可以看出：在制憲之際我國政黨政治尚未發達，制憲者的關懷重心顯然是選舉的廉潔與公正、公開及公平。就條文結構而言，憲法第129條之「本憲法別有規定」乃指憲法本文中之正副總統與監察委員的間接選舉而言⁸⁰，故憲法第12章之內容當然不僅限於人民行使參政權而言，尚包括憲法所規定的其他選舉⁸¹。此外，憲法本文有關立法院與監察院同意權之行使，其雖不屬選舉，但亦應有第129條之適用。就情境結構而言，議長賄選問題是我國長期存在的問題。立委選制改制後，看似緩解賄選問題，但在兩黨制逐步發展但兩大黨卻又殊死纏鬥的格局下，使得議長中立化顯得格外重要。在此情境下，強化黨紀顯然不是一條該走的路。更何況所謂「責任政治」的價值追求並非建立在立委與其所屬政黨之間的人事決策上，而應是行政與立法兩權之間就公共政策所為的決斷。

若再以憲法特有的解釋原則來看，首先立憲主義既以節制權力為目的，在解釋上自不應朝相反的方向發展。若是把立法院院長選舉方式透過解釋而將其視為是國會自律的一部分，除了會與憲法第66條與第129條產生扞格之外，甚且這種透過解釋而賦予政治行動

80 相同見解如林紀東，中華民國憲法逐條釋義（四），頁209（1984年）。林俊益大法官在司法院釋字第769號解釋的部分不同部分協同意見書中，一方面認為「本憲法別有規定」係指憲法本文中總統及監委之選舉而言，但在另一方面也認為立監兩院正副首長之選舉亦屬「憲法別有規定」的範疇。問題在於此種解釋有以下二疑點：其一，「委員互選」若屬「別有規定」，其規定內涵為何？是違反普通、平等、直接或無記名？其二，就算因委員互選不屬普通選舉，難道也意謂著可以違反平等、直接及無記名要求嗎？

81 林紀東氏指出：「故各國憲法，多於國會議員或總統之選舉上，規定其選舉方法。我國憲法，因由選舉產生之人員甚多，如於有關各條分別規定其選舉方法，不免繁瑣，故於本條為綜合之規定，其立法技術，自甚可取。」引自林紀東（註80），頁198。換言之，憲法對於諸如總統、監委等國家機關之選舉方式，豈會完全不予規定？而可以解釋為：憲法僅規定總統與監委為間接選舉，至於應否平等或無記名等重要事項，可由立法者自為決定？

者自由的作法；根本與立憲主義精神相違背。

次再就比較法來看，「由47個歐洲國家組成之「歐洲委員會」(The Council of Europe)組織下專事法治研究的Venice委員會，於2007年10月23日公布其2005/351號研究報告。該報告針對31個歐洲國家的國會選舉或是人事同意權的投票規定進行調查，其調查報告首先指出：對於秘密投票原則，所有被調查的國家或由憲法，或由法律予以規定，它乃是人民參與普通、直接選舉的根本原則。就算有國家沒有透過憲法或法律明確規範此原則，在實踐上人民所參與之投票必須採秘密原則，可謂各國皆然，無一例外。至於非由人民所參與之投票，法國、比利時、荷蘭與亞美尼亞等四國也以明確的法規範規定秘密投票原則適用於各種類型之選舉，包含議會內之選舉。其次，不論有否法規範明確予以規定，各國有關國會議員「針對人的投票」，絕大多數的國家都是遵守秘密投票原則。少數允許此類投票行為得採公開記名方式的僅有英國下議院，愛爾蘭、波蘭、馬爾他與安道爾。該報告進一步指出：雖然「對人秘密」是原則，但也少有針對違反秘密投票之行為進行制裁，至多是以議會紀律規定給予亮票者停權處分，或是所投之票被視為是無效票⁸²。歐陸國家多採議會內閣制，原則上應該格外重視黨紀，對於議員的投票行為，自該採記名投票原則；但絕大多數歐陸國家卻採秘密投票制度，此實與投票所涉及之職位相關。更詳細地說，當投票所涉及之職位必須保持中立，必須去政黨化時，在制度設計上就必須採取秘密投票制度。故國會議員「針對人的投票」中，諸如選總理或總統，此應屬黨紀得以規範之範疇，自得採記名投票。反之，諸如憲法法院法官、監察使或檢察總長等職位，既以去政黨化與中立化為原則，則當然應該採取秘密投票制度。

82 所謂「針對人的投票」，包括選舉總統或內閣總理，以及諸如憲法法院或最高法院法官、中央銀行行長、審計長、檢察總長、監察使或通訊傳播委員會委員等人員之人事同意權。引自吳庚、陳淳文（註37），頁718。

最後，在結果是否務實的考量下，議長選舉記名投票在中央立法院層級，完全不會讓議長得以中立化⁸³，在地方議會層級，則更不會產生有效改善賄選的效果。湯德宗大法官在司法院釋字第769號的不同意見書指出本號解釋「後果堪慮」，因為若下次立法院修法再改為秘密投票，大法官也只能宣告為合憲⁸⁴。試想一時的國會多數可以將議長選舉方式恣意變更，這就像我國過去針對議會議長選舉亮票行為的法律後果，有的遭受刑事制裁，有的卻又完全豁免，制裁與否端視檢方如何認定「技術性亮票」與是否起訴，以及法院是否處刑。過去亮票時而受罰，時而又合法，以及今後能否亮票全視一時之立法院多數黨的意志來決定，這豈是正常民主法治國可以容許的情境？

二、司法院院長人事案

2016年司法院院長人事案因被提名人已曾任八年大法官而引起喧然大波，批判此舉為違憲者的主張，乃立基於憲法增修條文第5條第2項：「司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任。但並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。」認為「不得連任」的意思就是終身不得再度出任大法官，或至少是要間隔已任過之任期（本案即是八年），才不違憲⁸⁵。認為此舉為合憲的主張，也是以此憲法條文為基礎，強調法律解釋必須始於文字，終於文字⁸⁶，既然法條用語是「不得連任」，自然就沒有「禁止再

83 2016年在民進黨大方亮票下當選的蘇嘉全院長，比過去任何一任立法院院長都還更加服膺於其所屬的政黨之領導。

84 不過，湯德宗大法官本號解釋不同意見書的重點乃在「受理與否」與「中央與地方之分權」上，對於憲法第66條與第129條的關係，並未觸及。

85 莊勝榮，許宗力再任大法官曲解憲法，中時電子報，2016年8月27日，<https://opinion.chinatimes.com/20160827003953-262105>（最後瀏覽日：2018年12月10日）。

86 許宗力，我對司法改革與大法官再任問題的一些看法，2016年9月1日，許氏如此表述：「總之，法律解釋，始於文義，終於文義，在文義許可範圍，有解釋空間，可能嚴格解釋，或擴張解釋，但無論如何，不能逾越文義許可範圍。連

任」，故只要沒有連任事實，即屬合憲⁸⁷。以下亦以三層次之結構分析，討論本案。

(一) 結構分析

1. 制度結構

就憲法條文結構來看，憲法本文對於大法官之規定見於憲法第79條，若連結憲法第81條來看，制憲者應認為大法官為憲法第80條及第81條的「法官」，其法定保障內容與其他法官相同⁸⁸。在此觀點下，大法官似應該先具一般法官的身分。只是立法者落實憲法規定時，並未限縮大法官僅能由一般法官中選任產生，而是採多元選才方式；因而有學者或其他法律工作者被選任為大法官。民國46年的司法院組織法規定大法官任期九年，且得連任。在此規定下，非一般法官出身的大法官在其任期屆滿後若未連任，則失去法官地

任的中文含意不難懂，就是一任任滿後無縫接軌繼續任下一任，修憲實錄也是舉過去大法官可以一屆屆的連任下去為例，說明修憲者對連任的理解，才規定以後禁止連任。既然憲法是規定不得連任，怎能超越文義，強解釋成也包括禁止再任，一生只能任職一次？……說真的，8年並不長，對很多大法官而言，經過開始的摸索、學習，再過一段時間鍛鍊，剛開始感到比較成熟、得心應手沒多久，倏忽就要卸任了。當初修憲時，將大法官任期從9年減為更短的8年，只禁連任，不禁再任，從經驗傳承與新陳代謝兩種法益之權衡來看，似乎也有其一定道理的。」

87 持此見解者眾，如錢建榮，憲法不禁止大法官再任——敬答陳志祥法官，上報，2016年10月25日，https://www.upmedia.mg%2Fnews_info.php%3FSerialNo%3D6310&usg=AOvVaw3d7nlVmPtwlrUgH4L4KFLG（最後瀏覽日：2018年11月9日）；彭錦鵬，大法官提名的憲政考量，蘋果日報，2016年8月9日，<https://tw.appledaily.com/headline/daily/20160809/37340415/>（最後瀏覽日：2019年10月18日）。

88 如司法院釋字第601號解釋文第1段謂：「司法院大法官由總統提名，經立法院同意後任命，為憲法第八十條規定之法官，本院釋字第三九二號、第三九六號、第五三〇號、第五八五號等解釋足資參照。為貫徹憲法第八十條規定『法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉』之意旨，大法官無論其就任前職務為何，在任期中均應受憲法第八十一條關於法官『非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸』規定之保障。法官與國家之職務關係，因受憲法直接規範與特別保障，故與政務人員或一般公務人員與國家之職務關係不同。」

位，此與憲法第81條的保障有違；故過去實際運作上除因年紀太大不宜再被提名或本人不願續任外，過去的大法官幾乎都是連任的。唯有如此，才能與憲法第81條的規範精神相近，以確保大法官的獨立性。

現行新制推翻過去「大法官以連任為原則」的規範精神與實務運作情形，直接明定「不得連任」，當時的修憲者顯然是以過去的「得連任制」讓大法官可能過於偏向執政者為理由，希望透過此次修憲強化大法官的獨立性。此外，雖然司法院釋字第601號解釋說「大法官為憲法第80條規定之法官」，但依憲法增修條文第5條第1項規定，非法官轉任之大法官，不適用憲法第81條規定。故大法官與一般法官在現行制度下已明確分流，法官是終身職，但大法官不是。

更重要的制度變革是有關司法院正副院長的部分，憲法增修條文第5條第2項規定：「並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。」然「任期保障」本就是確保司法獨立最重要的制度安排，修憲條文竟將司法院正副院長的任期保障去除，顯見此次修憲思維十分粗糙混亂。在總統有權決定司法院正副院長的人選，且正副院長職位又無任期保障的情況下，讓眷戀職位的司法院正副院長更加不容易獨立。毫無疑問地，「可再任之大法官」加上「無任期保障之正副院長」正好是摧毀司法獨立的最佳配方。

2. 情境結構

我國不論是立法、修法、乃至修憲，或因參與者專業素質低，或因政治鬥爭激烈，或因非公益考量太多，或因受限於時間，導致法律條文往往十分粗糙，甚至也會出現錯誤或闕漏⁸⁹。以本案大法官不得連任之新制的修憲程序為例，本身就是修憲過程中的意外插

⁸⁹ 例如司法院釋字第470及541號解釋。

曲，全然不是事前規劃，並經過認真審議程序而產生的修憲條文。故此次要被解釋的條文本身，本來就是一份不夠嚴謹的文本。基此，要判斷當時修憲者使用「不得連任」的真意，究竟有否包含「再任」的意思，光看「文字」本身顯然是不足的。

其次，新制所設計的交錯任期制，歷經十餘年的實際運作後，已經被徹底破壞。原本希望大法官與政治權力部門間的互動關係儘量簡化，現今卻已完全改觀。以本案為例，2016年5月上任的總統，先在2016年提名7名大法官，接著在2019年又可再提名4名，也就是在其短短4年任期內，已提名了11名大法官。如果現任總統連任，則在其卸任前可以實現所有大法官皆由其所提名。從總統行使其提名權的角度來看，原來設計的交錯任期制限制每任總統的提名次數與提名人數，但幾經運作之後，原來的制度理念已被完全破壞。

再者，立法院選制改革後，兩大黨格局已成。大法官是否能夠獨立的考量，當然不是僅以擁有提名權之總統為限，而是還要及於總統所屬之政黨或政治勢力。換言之，在兩大黨輪政的情況下，大法官要討好的對象，絕對不會是僅限於特定人（總統或潛在的總統候選人）而已，而是包含特定之政黨或政治勢力。

最後，現行立法院的政黨組成結構，以及立法院行使同意權的方式與簡單多數的同意門檻，根本上是促進黨同伐異，而非以當事人是否適任為審查重點。在此背景下，有志於大法官一職的人，或是想要再任大法官的現任大法官，自然更會向政黨靠攏，以表忠貞。

3. 價值結構

司法獨立是所有民主體制所不可或缺的前提要件，包括大法官在內的所有司法人員，都應該不受政治權力部門的權力誘惑，以致

喪失自己的獨立地位；故司法獨立無疑是本案的首要價值。

節制權力與保護少數既是憲法存立的目的，也是違憲審查制度所應發揮的功能。為實現此功能，大法官必須與政治權力部門，特別是與掌握國家公權力的執政黨與國會執政多數保持距離，劃清界線。故切斷大法官與政治權力部門的互動關係，亦屬本案所欲追求的價值。

（二）解釋操作

學界有關再任合憲與否的討論甚多，但大多沒有全盤考量制度、情境與價值等不同面向，並以憲法解釋原則作為其上位指導。然而就算僅以傳統的法律解釋方法來分析，「再任合憲說」依然很難予以證立。

以文義解釋支持再任合憲的說法看似強而有力，但事實上卻弱不禁風。前文提及「任何車輛不得進入公園」、德國法學家賴特布魯赫（Gustav Radbruch）的「禁止帶狗進教室」與德國有關鹽酸酸是否是屬於武器等案例⁹⁰，即可輕易說明「再任合憲」的推論甚難成立⁹¹。在另一方面，扣緊法條文字，進而主張「法未有明文禁止，即屬允許」的說法，根本完全不思考規範的對象為公權力機關而非人民，立憲主義節制國家權力的想法完全沒有列入考量⁹²。至若歷

⁹⁰ 吳庚（註4），頁511。

⁹¹ 吳信華氏以我國釋憲實例指出：憲法第61條第2項規定立法院得邀請相關人員到會備詢，依文義解釋，「邀請」當然不具強制力，但司法院釋字第461號解釋卻認為受邀請之政府人員有出席義務；由此可見憲法解釋絕不是扣緊文字的文義解釋而已。參見吳信華，大法官任滿後的再任問題，月旦法學教室，170期，頁44-45（2016年）。

⁹² 例如劉幸義氏如此表述：「幾十年來每當有爭議問題發生，而該問題又沒有法律條文規定，公權力機關處理，處於永遠的贏家，因為公權力機關想做的或有利於己的，處理漏洞的結論是『法無禁止』；不想做的或不利於己的，其結論則是『於法無據』。我們經常會看到或聽到對造當事人（主要是民眾）異常氣憤，卻又『無言以對』，不知如何是好。造成此類兩極端不同結論的原因，一方面固然是公權力機關居於掌權的優勢，另一方面則是主事者雖有法條知識，

史解釋，除了修憲國民大會修憲時的真意無法探究並難以被確認外，從個別國大代表的發言意見，也無法看到明確支持「再任」的表述⁹³。還有以體系解釋之名，把已無屆次概念的大法官與司法院院長之職務，與有明確屆次區分之行政首長與民意代表的選舉相比擬，此種完全不考慮司法獨立之重要性與特殊性的謬誤類比，自不足採。最後，採目的解釋者，在強調民主課責之際，卻忽視司法獨立與民主課責存有本質上的衝突；或是認為「再任」可以回收再利用法律菁英的說法，也有阻礙大法官新陳代謝的副作用。尤其他們忽視大法官交錯任期制已徹底被破壞，每位總統可提名的機會變多，兩大黨或兩大政治勢力交替輪政的格局已經成形，且政權輪替的週期愈來愈短，法律菁英或在任大法官押寶表態的動機愈來愈強，司法獨立遭致侵害的風險，不僅沒有降低，反而是與日俱增。

回到問題的本質，並以前述憲法解釋原則來分析：切斷大法官

但欠缺法學知識。」引自劉幸義，大法官的「再任」，法無禁止？於法無據？，風傳媒，2016年9月7日，<http://www.strom.mg/article/162254>（最後瀏覽日：2016年12月16日）。

- 93 例如彭錦鵬代表的發言紀錄：「本案最大的特點，是參考世界各國的成例後而做的規定，世界各國大法官的任期，均在8至10年間，不連任佔多數，我們希望大法官會議能具超越政黨，超越總統任期，並且能對國民大會負責，這是我們設計的方向。大法官不能連任，可免除其在釋憲時，存有爭取連任的心理，否則對釋憲案或許會產生不良影響，我們期盼大法官能全心全意投入釋憲工作。」（第三屆國民大會第二次會議第二十六次大會速紀律第51頁修正案第二十二號說明）楊敏華代表之發言紀錄：「在任期部分，目前大法官任期九年，且可連選連任不受限制，因此曾有大法官一口氣連任了二十七年的例子，而大法官的工作為何？不過是舉手罷了。以前的大法官因為扮演御用學者，御用大法官的角色，因此在參加大法官會議時只要舉手即可，一舉手就能連任，一連任就是二十七年，甚至是去世時都還要覆蓋黨旗、國旗，這是很不可思議的。大家都希望大法官能本著良知來解釋憲法及統一解釋法令，因此我們明文規定不管任期為九年或十二年，都不能讓大法官有連任的機會，不給予他們享有一輩子榮華富貴希望。如此一來，他們就會因為自己再也沒有機會擔任大法官而戰戰兢兢的本著良知良能來解釋憲法，扮演憲法守護神的角色。」（第三屆國民大會第二次會議第二十六次大會速紀律第52頁修正案第九十五號說明）彭氏發言表示「大法官不應存有爭取連任的心理」，在此發言脈絡下，當可推斷彭氏必然也認為「大法官不應存有爭取再任的心理」。至於楊氏發言指出「再也沒有機會擔任大法官」，當然就是排除再任的可能性。

與政治權力部門間的互動關係，才是維繫司法獨立最重要的一件事。試想連一般法院的法官，在其任命之後，基本上就不再由政治權力部門掌握其職業生涯之發展，任何職位變動乃基於法官本人之意願，且法官也應無升遷概念。司法院釋字第539號解釋對於庭長職務的調動，也強調庭長係「行政性質」，而與法官本質無涉。憲法第81條的規範目的，就是要盡其可能地切斷法官與政治權力部門之間的所有千絲萬縷的連結關係。故法官一經任命，就不該再受政治權力部門左右或影響。基此理解，大法官作為一種法官，其獨立性要求不可能亞於一般法官。為確保其獨立性，制度上只有兩種選擇：一是「終生制」，一是「固定任期，不得重任制」；前者如美國，後者如德國、義大利或法國；此二種制度設計有一個共同的規範重點：**任命次數僅能有一次**，就如同一般法院法官的任命一樣。

我國舊制讓大法官任命次數超過一次以上，客觀上的確可能減損大法官的獨立性。但是因其任期長達九年，且實務上又以連任為原則，故才能在一定程度上降低其損害。以此想像，**破壞獨立性最糟的制度設計就是「任期短，可重任」**，如此不斷出現任命時點，不斷地強化政治權力部門對任命機關的支配力。典型的例子如國家通訊傳播委員會組織法第4條的「任期四年，任滿得連任」，或是中央選舉委員會組織法第3條「任期為四年，任滿得連任一次」。通傳會或中選會雖非法院，但屬獨立機關，應特別強調其獨立性。但是前述任期設計制度讓這些機關很難獨立運作，根本上它們都成為行政院의 傀儡機關或附隨組織。

從立憲主義節制國家權力的角度來看，「任期限制且不得連任」的設計是屬於限制權力事項，而不是賦權事項。它一方面限制了提名者（總統）與同意者（立法院）的人事權，另一方面也限制了「被任命者」（大法官）行使權力的期限。對於限制權力的憲法規範，在解釋上應以落實限制權力之效果，以達「節制權力」為最高指導，而不應透過解釋導致受規範對象反而可自由行使其權力。

很顯然的，「可再任說」的困境在於「再任合憲」的解釋竟可擺脫並架空了「任期限制」的憲法規範意義。不論是卸任後五天、五週、五個月還是五年後再任，只要與原任期屆滿後有所間隔，「可再任說」都認為此種情況即非「連任」，故屬合憲。依此解釋方法，「任期限制且不得連任」的制度設計，其規範意義何在？更致命的是：「間隔多久」後再任才是合憲的再任？是「可再任說」一直無法說清楚的部分⁹⁴。

從憲法忠誠的角度來看，修憲原意是要「限制任期」，若是支持「再任合憲說」，其解釋的實質結果竟是「大法官無任期限制，只要中間出現間斷即可。」至於間斷期間的長短為何？因法無明文規定，故可任意為之。此種解釋結果恰與修憲原意相反，豈是忠誠於憲法的表現？

再從比較法來看，固然有人舉出諸如韓國、柬埔寨、印尼、蒙古、緬甸等國都不禁止再任，進而推導出禁止再任非普世原則。但又有哪些成熟的民主法治國的制度設計是採「可再任制」？這種允許再任之制度設計，普遍不被成熟民主法治國所接受的原因，是解釋者不能不知，更不能視而不見的部分。

最後，從結果是否務實的角度來看，「可再任說」的解釋結果讓某些大法官的任命次數可能超過一次以上，他們與政治權力部門間的互動關係無法一刀切開，徹底了斷；反而是重續那些人與人之間本就存在的千絲萬縷。特別是在現今我國交錯任期制已遭實務完全破壞，且政黨鬥爭對抗極為激烈的情境下，更有讓在位者難安其位的誘因，總會有人在任職期間不免要為再任而做準備；這樣的解釋結果實難謂為務實。

94 對此問題，許宗力氏認為四年是妥當的，彭錦鵬氏則稱兩年即可，但莊勝榮氏認為至少應八年。但不論是幾年，其判斷基準何在？

陸、結語

憲法解釋攸關民主鞏固與法治發展，影響憲政運作至鉅。憲法解釋學固然是法律解釋學的一部分，但基於憲法之位階地位與抽象審查之特性，其比一般法律解釋學更需要框架與節制，以及指引與方法。而憲法解釋原則就是指引憲法解釋行為的最高指引與誡命，用以節制有權憲法解釋者之憲法解釋權。吳庚教授在其大作中提出四個專用於憲法解釋的規則，作為憲法解釋之指引。本文從吳氏所提之諸多憲法解釋方法中，萃取出四項解釋原則，作為我國現今進行憲法解釋時應優先考量的原則。換言之，憲法解釋原則係引導解釋方法之選用與解釋內容之決斷，是駕馭解釋行為的上層指導。這些解釋原則除了來自一般法律所通用的解釋方法外，更透過考量特定法體系之「制度」、「情境」與「價值」等面向，進而形塑出具有各自特色的憲法解釋原則。

憲法解釋學，乃至一般法律解釋學，究竟是一門科學？還是非科學？是主觀？還是客觀？雖然對此問題學界爭論不休，但是文本，文本所形成的制度，制度運作情況與結果，以及制度運作的背景環境與脈絡等，都是客觀的存在。它們既可以成為研究客體，也可成為拘束解釋者之自由意志的外在客觀框架。雖然解釋行為的確是有一部分屬於「認知」性質，但無可否認地，亦有另一部分是屬於「意思」與「創造」性質。一旦外在客觀框架愈清晰綿密時，則解釋者的創造空間就相對限縮。反之，解釋者的意志即可能大幅影響被解釋之法規範的實際內容。由於憲法文本多屬概括抽象，尤其需要憲法解釋原則之輔助，以免釋憲者因解釋權無法被外界檢驗而成為一種不被節制的恣意權力；他們有可能為媚求己利而成為政治權力部門的附庸，或是有如不被控制的脫韁野馬，僭越成為立法者，或甚至是修憲者。這也就是為什麼凱爾生論及憲法設計時，特別強調兩個要點：一是為了避免憲法法官僭越其權力，憲法條文應

當儘量避免使用諸如「自由」、「平等」與「正義」等過於抽象籠統的用語⁹⁵；二是如果憲法無可避免地必須使用這類相當抽象籠統的用語時，就必須禁止憲法法院法官以這些抽象籠統的概念用語作為違憲審查的基準⁹⁶。只可惜凱爾生的理想與各國所操作之違憲審查現實差距甚大，因此更需要有得以框限並節制解釋權的憲法解釋原則。

誠如吳庚教授所言：「無論從事學理研究或實務工作者，對於憲法的解釋與適用，當然不必預先限定某種解釋方法，非加以套用不可，致遭膠柱鼓瑟之譏；但對方法論仍應有一定的認識，在思維過程中不能完全不受拘束，對於個案所獲致的結論，也應運用方法論作一番自我檢查，才能在公諸於世之後，承擔起公評與考驗。⁹⁷」憲法解釋原則其實就是解釋憲法的上位指導原則，用以節制解釋者之解釋權，同時指引解釋者的解釋行為；解釋者不僅得以之作為引導啟發與自我檢查的工具，並得作為外界據以檢驗及批判解釋結果的論證基礎。

95 凱爾生如此表述：「當法院適用憲法條文時，特別是如適用憲法基本權利條款以決定法律案之內容時，這些憲法條文不應以過於抽象的語句來形塑，而且不應使用諸如『自由』、『平等』、『正義』等模糊用語。若非如此，則將可能發生憲法上所未允許，且也在政治上不適當的權力移轉現象，也就是國會的權力將移轉到國會之外之外部機構，而此外部機構所行使的此種政治性權力，是完全不同於國會所代表的權力。」KELSEN (H.), *La garantie juridictionnelle de la Constitution*, Paris, Marcel Giard, 1928, p. 239.

96 TROPER (M.), *L'interprétation constitutionnelle*, in MÉLIN-SOUCRAMANIEN (F.), *L'interprétation constitutionnelle*, Paris, Dalloz, 2005, p. 14.

97 吳庚（註1），頁6。

參考文獻

1. 中文部分

- 吳庚（1990），論憲法解釋，法令月刊，41卷8期，頁3-6。
- （1993），法律解釋學初探，法令月刊，44卷9期，頁3-6。
- （2003）憲法的解釋與適用，臺北：自版。
- （2004），憲法的解釋與適用，3版，臺北：自版。
- 吳庚、陳淳文（2019），憲法理論與政府體制，增訂6版，臺北：自版。
- 吳信華（2016），大法官任滿後的再任問題，月旦法學教室，170期，頁43-49。
- 林子儀（2001），憲政體制問題釋憲方法之應用——美國聯邦最高法院審理權力分立案件之解釋方法，司法院大法官九十年度學術研討會，司法院主辦，2001年10月13日。
- 林更盛（2012），論法律解釋的目標，高大法學論叢，7卷2期，頁1-40。
- 林紀東（1984），中華民國憲法逐條釋義（四），臺北：三民。
- 林超駿（2002），Scalia大法官之憲法解釋觀——原意主義者之回應與展望，憲政時代，28卷2期，頁79-98。
- （2006），美國法上有關原意主義辯論之例示與啟示——以Scalia大法官之見解為中心，收於：超越繼受之憲法學——理想與現實，頁123-185，臺北：元照。
- 許宗力（1999），憲法與政治，收於：憲法與法治國行政，頁39-46，臺北：元照。
- 陳弘儒（2017），美國憲法解釋理論的新發展——新原意主義的方法論與中立化主張，第11屆「憲法解釋之理論與實務」學術研討會，中央研究院法律學研究所主辦，2017年11月14日。

陳淳文(2014)，釋憲機關的司法權威——由法國與我國違憲審查實務來看司法權威的建立，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務(八)(下冊)，頁379-443，臺北：中央研究院法律學研究所。

——(2016)，法治社會之司法權威初探，收於：陳春生編，法之橋：臺灣與法國之法學交會——彭惕業教授榮退論文集，頁27-50，臺北：元照。

蘇彥圖(2017)，憲政民主的死人之手問題——憲法規範權威的初步反省，收於：李建良編，憲法解釋之理論與實務(九)，頁135-199，臺北：中央研究院法律學研究所。

2. 外文部分

Bobbitt, Philip. 1982 *Constitutional Fate: Theory of the Constitution*. New York, NY: Oxford University Press.

Cayla, Olivier (1992), La Notion de signification en droit, Thèse, Paris II.

——(1998), Le Coup d'Etat de droit, Le Débat, n° 100, pp. 108-133.

Dupré, Catherine. 2003. *Importing the Law in Post-Communist Transitions*. Oxford: Hart Publishing.

Elliot, Robin. 2001. References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of Canada's Constitution. *Canadian Bar Review* 80:67-142.

Fuller, Lon L. 1958. Positivism and Fidelity to Law, A Reply to Professor Hart. *Harvard Law Review* 71:630-672.

——. 1964. *The Morality of Law*. New York, NY: Fawcett Publications.

Hart, H.L.A. 1958. Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review* 71:593-629.

Kelsen, Hans (1928), La Garantie juridictionnelle de la Constitution, Paris: Marcel Giard.

- (1962), *Théorie pure du droit*, traduit par Eisenmann (C.), Paris: Dalloz.
- L'Heureux-Dube, Claire. 1998. The Importance of Dialogue: Globalization and the International Impact of the Rehnquist Court. *Tulsa Law Journal* 34:15-40.
- Millet, François-Xavier (2013), *L'Union européenne et l'identité constitutionnelle des Etats membres*, Paris: LGDJ.
- Perelman, Charles (1999), *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, 2^e éd., Paris: Dalloz.
- Ricoeur, Paul (1995), Le Problème de la liberté de l'interprète en herméneutique générale et en herméneutique juridique, in Amselek (P.), *Interprétation et droit*, pp. 177-188, Bruxelles: Emile Bruylant.
- Rousseau, Dominique (2011), L'Identité constitutionnelle, bouclier de l'identité nationale ou branche de l'étoile européenne, in Burgorgue-Larsen (L.), *L'Identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe*, pp. 89-100, Paris: Pedone.
- Slaughter, Anne-Marie. 2003. A Global Community of Courts. *Harvard International Law Journal* 44:191-220.
- Tripathi, Pradyumna K. 1957. Foreign Precedents and Constitutional Law. *Columbia Law Review* 57:319-347.
- Troper, Michel (1994), *Pour une théorie juridique de l'Etat*, Paris: PUF.
- (2001), *La Théorie du droit, le droit, l'Etat*, Paris: PUF.
- (2005), L'Interprétation constitutionnelle, in Mélin-Soucramanien (F.), *L'Interprétation constitutionnelle*, pp. 13-25, Paris: Dalloz.